



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 344/12

בפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

- התובעים:**
1. עופר בביאן ת.ז. 069441384
 2. ציונה בביאן ת.ז. 022260574
 3. יוסף אהרונסון ת.ז. 1371689
 4. מלכה אהרונסון ת.ז. 66762
 5. דוריס שלזינגר ת.ז. 012681706
 6. צפורה הולנדר ת.ז. 13656269
 7. עזבון המנוח נפתלי הולנדר ת.ז. 01365625
 8. ע"י הגב' צפורה הולנדר ת.ז. 13656269
 8. קארל לרנר דרכון 442062596
 9. חני גרוס ת.ז. 5544713
- ע"י עו"ד רמי בביאן

- נ ג ד -

- הנתבעים:**
1. דוד ריימונד ת.ז. 021356233
 2. ריקלה ריימונד
 3. יעקב גולדפילד ת.ז. 036114973
 4. רבקה גולדפילד
- ע"י עו"ד יעקב אמסטר ועו"ד רועי שניר

פ ס ק - ד י נ

עניינו של פסק דין זה בהרחבת דירות הגג של הנתבעים, אל חלק משטח גג הבית המשותף.

העובדות הצריכות לעניין

1. עסקינן בבית משותף המצוי בשדרות אשכול 2 בירושלים והידוע כגוש 30246 חלקה 6 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף כולל 3 כניסות, שבכל אחת מהן 24 דירות, ובסך הכל מונה הבית המשותף 72 דירות.
2. התובעים הנם בעלי דירות בכניסה ב' של הבית המשותף. התובעים 1 ו-2 בעלי זכויות החכירה בתת חלקה 27, התובעים 3-4 בעלי זכויות החכירה בתת חלקה 33, התובעת 5 בעלת זכויות החכירה בתת חלקה 35, התובעים 6-7 בעלי זכויות החכירה בתת חלקה 42, התובע 8 בעליה של תת חלקה 44, התובעת 9 היא בעלת מחצית מזכויות החכירה בתת חלקה 43.
3. הנתבעים הם בעלי זכויות בדירות הגג של כניסה ב' בבית המשותף. הנתבעים 1-2 בעלי זכות החכירה בתת חלקה 47 והנתבעים 3-4 בעלי תת חלקה 48.
4. לבית תקנון מוסכם אשר נרשם ביום 20.2.94. בתקנון המוסכם נקבע, בין היתר, ההוראות הבאות:

בסעיף 1 לתקנון המוסכם נקבע כך-

"בהתאם לאמור בסעיף 59 לחוק אנו קובעים בזאת כי הרכוש המשותף או חלק ממנו שבתחום כל כניסה (למעט הקרקע) יהיה צמוד לדירות שבאותה כניסה בלבד ולפיכך, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף הנ"ל על כל בעלי הדירות שבאותה כניסה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הבית מורכב ממבנה אחד בן שלוש כניסות ובכל כניסה 24 דירות כדלקמן:

כניסה א' כוללת את דירות 6/1 - 6/24 ועד בכלל. כניסה ב' כוללת את דירות 2/25 - 6/48 ועד בכלל. כניסה ג' כוללת את הדירות 6/49 - 6/72 ועד בכלל.

לכל כניסה מתקנים המשמשים אך ורק את בעלי הדירות באותה כניסה כגון: המקלט, חדרי המדרגות, למעט חדרי ההסקה המצויים בתחום כניסות א' ו-ג' ומשמשים את כל הדירות בבית".

סעיף 2א לתקנון המוסכם קובע:

"הרכוש המשותף או חלק ממנו שבתחומי כל כניסה והשימוש בו הוא ייחודי לגבי אותה כניסה יהיה צמוד לדירות שבאותה כניסה"

5. הנתבעים ביקשו להרחיב את דירותיהם ולשם כך לעשות שימוש בחלק משטח הגג המצוי מעל דירות כניסה ב'. אי לכך, פנו הנתבעים אל מוסדות התכנון בבקשה לקבלת היתר כדן. לאחר דחיית ההתנגדויות, ביום 20.11.12 קיבלו הנתבעים את היתר הבניה המיוחל להרחבת דירותיהם (נספח ב' לכתב ההגנה).
6. עם ביצוע העבודות בהתאם להיתר הבניה, הוגשה ביום 26.12.12 התביעה דנן במסגרתה מבוקש ליתן צו מניעה קבוע האוסר על ביצוע כל פעולה של בניה ברכוש המשותף ובפרט בגג הבית המשותף, וכן ליתן צו להריסת כל הבנייה שביצעו או יבצעו הנתבעים ברכוש המשותף. לחלופין בלבד, התבקש לחייב את הנתבעים בתשלום דמי איזון.
7. בדיון שהתקיים ביום 20.2.13 הוגדרו הפלוגות העיקריות בהן יש לדון במסגרת הליך זה. כמו כן, בהחלטתי מאותו מועד קבעתי, בין היתר, כי- **"במידת הצורך, יקבעו הליכי הדיון בעניין דמי האיזון לאחר הכרעה בפלוגתאות עליהן סוכם, וככל שיהיה בכך צורך"**. בהמשך ההליכים הוצע, הן על ידי ב"כ הנתבעים והן על ידי, כי המשך ההליך יתמקד בתשלום דמי איזון, תוך ויתור על הבקשה למתן צו הריסה. ב"כ התובעים, לאחר ששקל הצעה זו, הודיע כי התובעים מתנגדים לכך ועומדים על קבלת צו ההריסה (ראה הודעת ב"כ התובעים מיום 4.6.13) לפיכך, לא נותר אלא להמשיך בהליך כסדרו.
8. ביום 5.3.13 ערכתי ביקור במקום. בביקור התברר כי בניית הרחבות דירות הנתבעים מצוייה בעיצומה וניתן היה להבחין בפועלים העמלים על ביצוע העבודות הנדרשות לצורך ההרחבה. יוער, כי התובעים לא פנו בבקשה למתן צו מניעה, אולם כפי שניתן היה להתרשם מהביקור במקום, עבודות הבניה היו בשלבי ביניים במועד הביקור ולפיכך יש גם להניח כי במועד הגשת כתב התביעה הייתה הבנייה בחיתוליה (יוער כבר עתה כי גם מהסכם הנתבעים עם הקבלן (אשר נדרש במהלך הליך גילוי ועיון במסמכים והועבר אף לעיוני), עולה כי מועד תחילת הבניה נקבע ליום 2.12.13 בעוד שהתביעה הוגשה ביום 26.12.12). מכל מקום, הטענה שהועלתה בכתב ההגנה לפיה התביעה הוגשה לכאורה "לאחר שהבניה נעשתה בפועל" (ראה סעיף כב' לכתב ההגנה) וכי "הנתבעים החלו בבנייה כבר לפני זמן רב ובנייתה הסתיימה זה מכבר" (ההדגשה לא במקור. סעיף 12 בעמ' 4 לכתב ההגנה), התבררה כבלתי מדויקת, ואינה עולה בקנה אחד עם המצב העובדתי לאשורו כפי שעלה מהביקור במקום.
9. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית ועדיהם נחקרו בישיבות שהתקיימו בימים 9.6.13, 18.6.13, 8.10.13.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ב. עיקרי טענות הצדדים

טענות התובעים

10. התובעים טוענים כי כשלושה שבועות לפני הגשת התביעה, באופן פתאומי וללא הודעה מוקדמת, החלו הנתבעים בביצוע עבודות בניה על גג הבית המשותף במטרה לספח אותו לדירותיהם. התובעים טוענים כי מימוש הבניה בהתאם להיתר הבניה יגרום לפגיעה קשה ושלא כדין בזכויותיהם של התובעים וכלל בעלי הדירות.
11. התובעים טוענים כי בניה זו מבוצעת מבלי שיש בידי התובעים את הסכמת 3/4 מבעלי הדירות ש- 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם כנדרש בסעיף 71 לחוק המקרקעין התשכ"ט- 1969 (להלן: "החוק").
12. לטענת התובעים, רף ההסכמות הנדרשות על פי סעיף 71 לחוק מתייחס במקרה דנן לרוב המנוי בסעיף מבין כל בעלי הדירות ולא רק מבין בעלי הדירות שבכניסה ב'. התובעים טוענים כי גישה זו מתחייבת מפרשנות התקנון המוסכם. לטענתם, סעיף 1 לתקנון המוסכם, הקובע את ההצמדות של חלק מהרכוש המשותף לכל כניסה וכניסה, קובע 2 מבחנים לקיומה של הצמדה כזו- פונקציונאלי וגיאוגרפי. לטענת התובעים, בסעיף 1 לתקנון המוסכם נקבע שישנם מתקנים המשמשים רק את בעלי הדירות שבאותה כניסה, ובסעיף 2 נקבע מה יהיה דינם של אותם חלקים אשר הוצאו מהרכוש המשותף הכולל והוצמדו לכל כניסה וכניסה. לטענת התובעים, בחינה מילולית ותכליתית של הדוגמאות המופיעות בסעיף 1 סיפא לתקנון מלמדת כי אין לכלול גם את הגג כמתקן מסוג זה שמוצמד לכל כניסה וכניסה. נטען, כי הגג איננה יחידה אשר נמצאת "בתחומי כל כניסה", והוא אף משמש מתקנים של בעלי דירות בכניסות אחרות.
13. כך נטען עוד, כי בניגוד לחדרי מדרגות, מעליות ומקלט, גג מעצם טיבו וטבעו לא נועד לשמש רק בעלי דירות של כניסה מסוימת. נטען, כי יש להבחין בין גג, הנצפה מבחוץ ויש לו משמעות ארכיטקטונית, למעלית, מדרגות או מקלט שהנם מתקנים פנימיים. ממילא נטען, כי במקרה דנן לא ברורים מהם גבולותיו של כל גג וגג. עוד נטען בהקשר זה כי אף התובעים, כפי שעלה מחקירתם, החלו באיסוף ההסכמות מכל 72 בעלי הדירות ורק בשלב מאוחר יותר החליטו שדי באיסוף ההסכמות מבין בעלי הדירות בכניסה ב' בלבד. לטענת התובעים, חיזוק לטענתם זו גם ניתן למצוא בדברי הנתבע 3 בחקירתו הנגדית, שם הוא אישר כי הכניסה לרכוש משותף שנותר על שטח הגג תבצע דרך כניסה א'.
14. לדידם של התובעים, היות ואף לשיטת הנתבעים אין בידיהם את הרוב הקבוע בסעיף 71 לחוק מבין 72 בעלי הדירות, הרי שיש לקבל את תביעתם מטעם זה בלבד.
15. התובעים מוסיפים וטוענים, כי אף אם היו אומרים שהגג המצוי מעל דירות כניסה ב' הוא גג הצמוד לכניסה זו, הרי שאין בכך דבר עם זכויות הבניה על הגג. לטענתם, כל עוד לא הוצמדו במפורש גם זכויות הבניה לאותו גג, לא ניתן לראות בהן כזכויות המוקנות לבעלי הדירות בכניסה ב' בלבד.
16. התובעים טוענים כי ממילא אין בידי הנתבעים את ההסכמה הנדרשת בסעיף 71 לחוק, גם לא מבין בעלי הדירות בכניסה ב'. נטען כי כלל לא הוכח שההסכמות ניתנו תוך הבנה מלאה למשמעותן, וכי לא התקיימה אסיפה כללית בה הוסברה המשמעות של ההסכמות. עוד נטען כי מי שחתם על ההסכמות לא הובא למתן עדות, ועל כן יש לראות בהסכמות אשר הוגשו בכתב כעדות שמיעה שאיננה קבילה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

17. עוד נטען מפי התובעים כי לא ניתן לקבל הסכמות של בן זוג אחד כאשר הזכויות בדירה מוקנות לשני בני הזוג, ועל כן יש לפסול הסכמות אשר ניתנו רק על ידי אחד מבני הזוג. טענה זו נטענה ביחס לתתי חלקות 25 (פשלה), 28 (וייס), 31 (ורדי-לגביו) נטען כי בעוד שמר ורדי חתם על הסכמתו - נספח א' לכתב ההגנה, חתמה אשתו הגב' ורדי על כתב ההתנגדות לבניה- נספח יט' לתצהיר התובע 1), 41 (פלדמן), 45 (קליק), 46 (מאיר). נטען כי במקרה דנן לא התקיימו תנאי חזקת השליחות מכוחה ניתן לראות בהסכמת אחד מבני הזוג ככוללת גם את הסכמת בן זוגו. התובעים טענו עוד כי לא הוזמן ולו אחד מבני הזוג להעיד ועל כן ממילא יש לראות בהסכמה הכתובה כעדות שמועה. בנוסף, ביקש ב"כ התובעים ללמוד מקל וחומר מפסיקת בתי המשפט אשר הכירה בזכויות בן זוג בדירה גם מקום בו הוא כלל איננו רשום כבעל זכויות במרשם המקרקעין.
18. עוד טענו התובעים כי הסכמות בעל פה להן טענו הנתבעים לא הוכחו כלל (כך ביחס לתת חלקה 26- שפירא דינה אסתר וכך גם ביחס תת חלקה 39- יהונתן תאומים).
19. כך גם נטען כי לגבי חלק מהדירות הוצגו מכתבי הסכמה, בעוד שאותם בעלי דירות הגישו התנגדויות לבניה למוסדות התכנון [כך למשל, ביחס לתת חלקה 34 (גולדברג), תת חלקה 31 (ורדי), תת חלקה 40 (ליונס), תת חלקה 45 (קליק). בהקשר זה טענו גם התובעים כי יש שוני בין חתימת משה קליק בכתב ההסכמה לבין חתימתו על ההתנגדות), תת חלקה 46 (מאיר)].
20. ביחס לתת חלקה 36, הרשומה בבעלות מדינת ישראל, נטען כי לא הוכח כי מי שחתם כל כתב הסכמה בשם מדינת ישראל (שמחה ליימן) הוא אכן הגורם המוסמך לחתום בשמה. נטען עוד, כי יש ליתן גם משקל לכך שבחקירתו הנגדית של הנתבע 3 התברר כי מר שמחה ליימן הוא גיסו.
21. באשר להסכמת בעלי הזכויות בתת חלקה 37 (פיליפ אברהם ופרל) נטען כי כפי שעולה מאישור רפואי מיום 20.6.10, מר פיליפ כלל לא היה כשיר ליתן הסכמתו והוא אף הוכרז כחסוי בבית משפט לענייני משפחה, על בסיס אישור רפואי זה. עוד נטען, כי אפוטרופסו, מר משה נוימן (להלן: "נוימן"), חתם על התנגדות לבניה בשנת 2011. לטענת ב"כ התובעים, כעולה מתצהיר עדותו הראשית של נוימן, הפך פיליפ לדמנטי שנתיים טרם מותו, היינו במועד מתן הסכמתו היה כבר דמנטי. בא כוח התובעים טען כי מר נוימן לא נחקר בחקירתו הנגדית כלל על האמור בהקשר זה בתצהירו, ולכן יש לקבלה כעובדה שהוכחה.
22. באשר לתת חלקה 38 נטען כי בעוד שהבעלים הרשום במרשם המקרקעין הוא ברגר טיבור, המחזיק מספר דרכון זר, הוצגה בנספח א' לכתב ההגנה הסכמתו של ברגר יעקב, לו מספר ת.ז. ישראלית.
23. בנוגע לתת חלקה 43 (רשומה על שם גרוס פרנק וחנה), נטען כי על אף שמר גרוס פרנק נפטר לא התקבלה הסכמת עזבונו. כמו כן עלתה הטענה כי הסכמתה של הגב' חנה גרוס בוטלה כשבועיים לאחר הינתנה ולכן אין לראותה כמי שהסכימה כלל. כהוכחת ביטול הסכמתה מבקשים התובעים להסתמך על עדותה של הגב' גרוס וכן על העובדה כי התשלום אשר עתיד היה להיות משולם לה, בתמורה להסכמתה, כלל לא שולם בסופו של דבר. עוד נטען, כי הגב' גרוס הגישה התנגדות לעירייה ועל כן לא ניתן להטיל ספק במהימנותה. כמו כן נטען כי כלל לא הוכח שהייתה הסתמכות כלשהי על הסכמתה ושינוי מצב לרעה בעקבותיה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

24. התובעים טוענים עוד, כי לצורך קבלת הסכמות בעלי הדירות פעלו הנתבעים באופן שממדר את בעלי הדירות זה מזה וכי הנתבע 3 עשה שימוש לרעה בתפקידו כיו"ר הנציגות על מנת לסכל קיומה של אסיפת דיירים.
25. לטענת התובעים, בעקבות הבנייה חלקים מהותיים מהרכוש המשותף הפכו להיות קניינם הבלעדי של התובעים, תוך שלילת האפשרות לצמיתות מחלק מבעלי הדירות לעשות בהם שימוש. נטען, כי הטענה שניתן יהיה כביכול להציב סולם לשם עליה לגג כפי שהיה בעבר הנה שקרית שכן בעבר כלל לא היה צורך בסולם.
26. עוד נטען לחוסר תום לבם של הנתבעים, שכן בכתב הגנתם טענו שהבנייה הושלמה, בעוד שמהביקור שנערך במקום התברר שהבנייה כלל לא הסתיימה והיא בעיצומה. דברים דומים עלו מעיון בהסכם הנתבעים עם הקבלן ממנו עלה כי הבנייה צריכה להתחיל לכל המוקדם בתחילת דצמבר 2012 בעוד שהתביעה הוגשה ביום 26.12.12.
27. באשר לטענות הנתבעים כנגד תום לבם של התובעים, נטען כי השימוש בהוראת תום הלב בכדי לשלול זכויות קנייניות הוא דבר חריג ונדיר, ולא בכדי, כך טוען ב"כ התובעים, הדגישו שופטי הרוב בפרשת רוקר נ' סלומון את הסכנה שיש במדרון חלקלק למוסד הבתים המשותפים. נטען כי זכותם של התובעים לשמור על קניינם וכי ברור לחלוטין שעל הבית המשותף חלה תמ"א 38.

טענות הנתבעים

28. הנתבעים טוענים כי ההלכה הפסוקה מובילה למגמה לפיה יש להעדיף את רעיון תמיכת הבנייה על פני מניעתה. נטען, כי דיני הקניין הקלאסיים הפכו את עורם בשנים האחרונות, באופן בו נכנסו דוקטרינות השוללות את התוצאות החדות והפוגעניות אשר היו בעבר.
29. נטען, כי רוח זו תחילתה בפרשת רוקר נ' סלומון (רע"א 6339/97, **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה (1) 199) והמשכה בספרו של חנוך דגן "קניין על פרשת דרכים", בגישה לפיה לא כל פגיעה ברכוש המשותף שתוצאותיה בעבר היו צו הריסה, או צו מניעה, יתקיימו היום. בהתאם לגישה זו, נטען, יש לאזן בין האינטרסים של כל הצדדים ולערוך בחינות שונות כגון מהי מידת הפגיעה הנתענת ברכוש המשותף, עד כמה הרכוש המשותף פוגע בשגרת חייו של המתנגד, האם ההתנגדויות נעשו בתום לב ונימוקיהן ענייניים, או שמא קיימים אינטרסים סחטניים.
30. לטענת הנתבעים, כאשר מדובר בניהול בית משותף קיימת חזקת הסכמה של בני הזוג שהם בעלים משותפים של דירת מגורים. לטענתם, לא ניתן לייחס טענות של פגיעה בקניין מקום בו קיימת הסכמתו של אחד מבני הזוג. בהקשר זה נטען כי פעולת הבנייה וההכנות לה הן פעולות מתמשכות ויש להניח שאם אחד מבני הזוג נתן הסכמתו במצב דברים בו יש מחלוקת בן בני הזוג, הדבר ימצא את ביטויו לאורך כל הליך הבנייה.
31. נטען, כי כאשר מדובר במשטר הבית המשותף, אין מקום להטיל על מבקש הבנייה נטל של בחינה טכנית, כמו במרשם המקרקעין. נטען, כי לדרישות פורמליות וטכניות אין לתת משקל עודף ומשמעותי לעניין ההסכמות. לפיכך, כך נטען, יש לראות, למשל, בהסכמת בת המתגוררת אחרי אמה בדירה, כהסכמת בעל הדירה גם מבלי שמוצג צו ירושה כדין.
32. לגופו של עניין נטען כי 7 בעלי דירות נתנו הסכמתם, וזאת אם כוללים בהסכמות גם את אלו שהסכימו על דרך חתימת אחד מבני הזוג (אשר לשיטת הנתבעים, כאמור, היא מספיקה). לעניין זה מפנים הנתבעים לבעלי תתי חלקות 28, 29, 32,



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

38, 41, 47, 48. בנוסף להם, כך נטען, 6 בעלי דירות נוספים הגישו התנגדויות ולאחר דחיית ההתנגדויות חזרו בהם ונתנו הסכמתם – בעלי תתי חלקות 25, 31, 34, 40, 45, 46.

33. מעבר ל-13 ההסכמות הנ"ל, נטען כי יש לקבל גם את ההסכמות על פה של בעלי תתי חלקות 26 ו-39. לטענת הנתבעים, הסכמתו של בעל תת חלקה 39, מר תאומים, הוכחה בעדותו של מר מנחם לובלינג (להלן: "לובלינג"), והסכמתה בעל פה של בעלת דירה 26, שרה שפירא המנוחה, ניתנה בעל פה באמצעות בתה- יורשתה, הגב' שרה (ג'וי) שפירא, אשר למרבה הצער נפטרה אף היא בינתיים. בהקשר זה נטען כי הפסיקה הכירה זה מכבר גם בתוקפן של הסכמות על פה.

34. בכל הנוגע לבעלי תת חלקה 37, פיליפ, טוענים הנתבעים כי האישור הרפואי מיום ה-20.6.10 איננו מהווה חוות דעת רפואית כחוק. ממילא, נטען, מדובר בתעודה המאוחרת למועד הסכמת בעל הדירה. יתרה מכך. לטענת ב"כ הנתבעים העובדה כי מתואר מצב רפואי של "דמנציה עם כושר שיפוט לקוי" איננה מעידה בהכרח על העובדה כי במועד מתן ההסכמה לא היה פיליפ כשר לתיתה. לטענת ב"כ הנתבעים, קיימות דרגות שונות של דמנציה ולא בכל הוכחת דימנציה יש בכדי לפסול מסמך משפטי שהחולה חתם עליה. כך למשל, נטען, כי לא כל דרגה של דימנציה תוביל לפסילת צוואה. לטענת ב"כ הנתבעים, מדובר במסמך רפואי כללי, ואין לקבוע בהתבסס עליו כי קודם למועד הוצאתו לא היה מר פיליפ כשיר ליתן הסכמתו. עוד נטען, כי אל מול מסמך זה ניצבת עדותו של הנתבע 3 אשר דיבר עם מר פיליפ והתרשם ממנו באופן אישי.

35. לגבי תת חלקה 27, בבעלות התובעים 1-2, טוענים הנתבעים כי בהסתמך על סעיף 71(ב) לחוק יש לראות בהם כמי שהסכימו קונסטרוקטיבית לבנייה, שכן הם עצמם ביצעו "הרחבה דומה" בדמות סגירת מרפסת בדירתם. לטענת הנתבעים, הרחבת דירה על פני שטח הגג משמעותית פחות מסגירת מרפסת, שכן בסגירת מרפסת נעשה שימוש בזכויות בניה המוקנות לכל הדיירים לעומת בנייה על גג הבית המשותף במקרה דנן, המקנה לכאורה מכוח תכנית 62 זכויות בניה ייחודיות רק לבעלי דירות הגג, ועל כן זכויות אלו אינן גוזלות מזכויות הבניה של יתר בעלי הדירות.

36. באשר לתת חלקה 43, נטען כי בעליה, חנה גרוס, לא הייתה רשאית לחזור בה מההסכמה לאחר שהנתבעים כבר הסתמכו עליה ושינו מצבם לרעה. לגופו של עניין נטען כי מחקירתה עלה ספק רב בנוגע לחזרתה מן ההסכמה. הנתבעים מדגישים עוד, שחקירתה העלתה כי טעמי התנגדותה נעוצים בסבלם של שוכרי דירתה מהבניה עצמה וכי היא כלל אינה מעוניינת במתן צו הריסה.

37. כמו כן מטיעוני הנתבעים עולה כי בידם גם את הסכמת תת חלקה 36, מדינת ישראל.

38. לפיכך נטען, קיימות הסכמות של לפחות 19 מתוך 24 בעלי דירות שהם מעבר ל- 3/4 מבעלי הדירות להם צמוד 2/3 מהרכוש המשותף, כנדרש בסעיף 71 לחוק.

39. ב"כ הנתבעים מוסיף וטוען כי התובעים הגישו את התביעה בחוסר תום לב ובהיעדר ניקיון כפיים, כן נטען כי התביעה נגועה בשיהוי ממשי. לטענת הנתבעים, התביעה הוגשה לאחר שהסתיים הליך ההתנגדויות ואף לאחר שהנתבעים החלו בעבודת שיפוץ השבילים לטובת יתר בעלי הדירות. כן נטען כי התובעים יכלו למנוע את הבנייה מראש אולם לא דאגו להוציא צו מניעה ולפיכך מדובר היום במעשה עשוי. בפועל, נטען, מעוניינים התובעים בפיצוי כספי ותו לא. לטענת הנתבעים, שיהוי זה אינו יכול להוביל את התובעים לזכות בסעד שמשמעו השבת המצב לקדמותו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

40. פן נוסף של חוסר תום לב נעוץ, לטענת הנתבעים, בטעמי ההתנגדות. לטענת ב"כ הנתבעים, וזאת בהתבסס על פרשת רוקר נ' סלומון לעיל, מעבר לעצם ההתנגדות לא הצביעו התובעים על כל סיבה להתנגדותם. לטענת ב"כ הנתבעים, יש לבחון מהם הטעמים העומדים ביסוד ההתנגדות ולתת לכך משקל. בעניין זה מפנה ב"כ הנתבעים אל פרשת רוקר נ' סלומון וכן אל פסקי הדין בשא (נצרת) 95/10, **חרושת מתכת בית השיטה (בהח) בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ - אגף אשראים מיוחדים** (פורסם ב"נבו" ניתן ביום 1.2.10), וכן ע"א 8661/10, **נעמה נ' טורקיה**, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 19.2.12.

41. באשר לסיווג הגג כחלק מהרכוש המשותף המוצמד לכניסה פרטנית או לאו, טוענים הנתבעים כי לצורך פירוש התקנון ניתן ללמוד מהתנהגות בעלי הדירות האחרים. ראשית, על אחד הגגות האחרים בניית הרחבה דומה הושלמה זה מכבר. שנית, מהעדויות עלה כי הטיפול בגגות השונים הופרד בין נציגויות הכניסות השונות. לטענת ב"כ הנתבעים, הפירוש הנכון לתקנון הנו שרק רכוש שלא ניתן לפצלו לפי כניסות הוא רכוש המשותף לכלל דירות הבית המשותף.

ג. דיון והכרעה

42. נפתח תחילה במסגרת המשפטית הרלוונטית לדיון ב"הרחבת בנייה" בבית משותף. לאחר מכן נבחן מה היקף ההסכמות המצויות בידי הנתבעים לשם הרחבת דירותיהם והאם די בה לצורך ביצוע הבנייה המבוקשת. ככל שיימצא כי הנתבעים אווזים בהסכמות הנדרשות כדין מבין בעלי דירות כניסה ב' בלבד, נמשיך ונבדוק האם די בכך, לאור אופיו של הגג המצוי מעל דירות כניסה ב', או שמא נדרשת הסכמה זו מבין בעלי הדירות בבית המשותף כולו, על שלוש כניסותיו. בהמשך, ובהתאם לצורך, תיבדק גם משקלן ומידת השפעתן של טענות הצדדים בדבר היעדר תום לב ושימוש לרעה בזכות, וכן נדרש לטענת השיהוי ומשמעויותיה.

43. אעיר, כי טענת התובעים בדבר הצורך בכינוס אסיפה כללית לשם קבלת ההסכמות כמו גם טענתם כי מדובר בבניית יחידות דיור נפרדות ולא בהרחבת בנייה, נזנחו הלכה למעשה בסיכומיהם ועל כן לא אדרש אליהן במסגרת פסק דין זה. מכל מקום, בפסק דיני בתיק 178/08 (הדן, על דרך המקרה, בבית המשותף שהוא נושא תיק זה) קבעתי כי אין הכרח לכינוס אסיפה כללית כתנאי לקבלת ההסכמות הנדרשות לצורך סעיף 71 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 ולפיכך אין לי אלא להפנות לקביעותיי ולאסמכתאות המנויות שם. כמו כן יש לציין כי טענת התובעים בדבר בניית יחידות דיור נפרדות שאינן הרחבות של דירות קיימות לא הוכחה כלל ואף לא גובתה בכל ראייה, כך שממילא לא מצאתי לה כל יסוד. אעיר בהקשר זה כי מהביקור שערכתי במקום לא התרשמתי כי אכן מדובר בבניית יחידות דיור נפרדות (אם כי יש להזכיר כי בשלב בו נערך הביקור הייתה הבניה בעיצומה וקשה היה לבחון את הטענה באופן מעמיק).

44. לא למותר לציין כבר עתה כי בין הצדדים התגלעה מחלוקת בשאלה על מי מוטל הנטל להוכחת ההסכמות. ככלל, מקום בו מבקש בעל דירה לבצע הרחבה על הרכוש המשותף, עליו הנטל להוכיח כי באמתחתו ההסכמה הנדרשת בחוק. העברת הנטל על כתפי הנתבע, בניגוד לכלל, נובעת מייחודיותה של ההוראה הקבועה בסעיף 71 לחוק, המתירה לרוב מיוחד לפגוע בקנייננו של המיעוט (ר' א. אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק ג', 211-213). זה גם הטעם לכך שעל מבקש ההרחבה להוכיח הסכמה פוזיטיבית לבניה המבוקשת, והוא לא יוכל לטעון להסכמה בהיעדר התנגדות של בעל דירה אחרת. יחד עם זאת, מבקש ההרחבה יצא ידי חובתו, בהצגת מסמך המעיד על הסכמה מפורשת כאמור, וככל שהציג מסמך כזה, הנטל להפריך את ההסכמה חוזר לכתפי התובע, ככל תובע שעליו נטל הראייה במשפט האזרחי



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

(ראה בהקשר זה גם פס"ד של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט בן ציון גרינברגר) אשר ניתן אך לאחרונה – עש"א (י-ם) 44078-10-12 כובאני ואח' נ' לוי ואח' (לא פורסם. ניתן ביום 19.12.13).

הרחבת בנייה

45. הכלל לפיו הצמדת רכוש המשותף לדירה פלונית דורשת את הסכמת כל בעלי הדירות קבוע בסעיפים 62(א) סיפה לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") – "... אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" ו-12(ב) לתקנון המצוי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות....".

46. במסגרת תיקון 18 לחוק (ס"ח 1518 תשנ"ה, עמ' 188, ה"ח 2303 התשנ"ד עמ' 629), ביקש המחוקק למנוע מהמיעוט את זכות הוטו שהוקנתה לו מתוקף הוראות 62 לחוק ו-12 (ב) לתקנון המצוי, כאמור לעיל. לפיכך, נקבע בסעיף 71 לחוק כדלהלן:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

47. בדברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש המשותף) התשנ"ה-1994 (הצעות חוק, התשנ"ה, עמ' 114) הובהר כך-

"מטרת הצעת חוק זו היא לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, במטרה למצוא פתרונות לבעיית צפיפות המגורים של משפחות רבות בדרך של הרחבת דירות קיימות או לבעיית צפיפות אוכלוסין השכיחה באזורים מסוימים בארץ, בדרך של בניה על הרכוש המשותף. על פי המוצע בסעיף 71 יהיו רשאים רוב בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, להחליט על שינויים ברכוש המשותף, אם מטרת השינוי היא הרחבת דירה קיימת אחת, או יותר, בבית המשותף. כיום, על פי הקבוע בסעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, החלטה זו טעונה הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף. דרישה זו מהווה מכשול מהותי ומוצע לשנותה. יחד עם זאת מוצע לקבוע במפורש מנגנון לפיצוי בעל דירה שנפגע באופן מהותי בדרך של תשלומי איזון.

48. המונח "הרחבה" מוגדר בסעיף 71 לחוק כ- "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף". בספרו של המלומד א. אייזנשטיין (ר': א. אייזנשטיין, שם, עמ' 223), נאמר כי- "כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה... יכולה הרחבה להיות אנכית, כגון, בניה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה, בניית פרגולה, בניה בחצר וחיבור התוספת שנבנתה לדירה קיימת בקומת הקרקע. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

49. הנה כי כן, במסגרת תיקון 18 לחוק נקבע חריג, המתייחס באופן פרטני לשינוי ברכוש המשותף על דרך של הצמדתו לצורך הרחבת דירה פלונית. לגבי שינוי או פגיעה במובן זה ברכוש המשותף, דורש המחוקק הסכמה ברוב מופחת מזה הנדרש לצורך הצמדת רכוש משותף לדירה פלונית, ככלל. יתרה מכך, המחוקק אף קובע הסדרים פרטניים באשר לבעל דירה שנפגע מקבלת ההחלטה "פגיעה מהותית" - וזאת על דרך מתן סמכויות רחבות למפקח להורות על שינוי, ביטול או התנאת ההחלטה בתנאים, וכן על תשלום דמי איזון לנפגע (ראה בסעיף 71 לחוק).
50. מהו, אם כן, טיב ההסכמה הנדרשת?
51. משמצאנו כי אין צורך שההסכמה תינתן במסגרת האסיפה הכללית, הרי שניתן להסתפק בהסכמה שניתנה על ידי בעל דירה באופן פרטני ובלבד שיהא ברור מתכנה כי בעל הדירה ויתר על זכותו הקניינית והסכים לניצול אחוזי הבניה (ר' למשל ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, פ"ד נ"ד(3), 389). כך למשל, חתימת בעל הדירה על תכנית בניה המוגשת לרשויות התכנון, עשויה להוות ראיה טובה לכך כי הוא הסכים לבניה המבוקשת, על כל המשתמע מכך (ראה דברי בית המשפט העליון בע"א 815/81 יעקב כליפא נ' אלי שאול, פ"ד לו(3), 78).
52. הנה כי כן, כל אימת שברור מההסכמה שהוצגה כי בעל הדירה ידע מה מהותה של הבקשה והסכים לבניה המבוקשת, יש לראות בכך הסכמה מצדו להרחבת הדירה וניצול אחוזי הבניה במסגרת סעיף 71 לחוק (השווה עוד: ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב, פ"ד מ(4), 673, וכן מ. דויטש, קניין [א], 695).
- על רקע האמור לעיל נפנה לבחינת היקף וטיב ההסכמות אשר הציגו הנתבעים.**
53. נפתח את הדיון בבחינת השאלה האם במקרה בו רשומות דירות במרשם המקרקעין בבעלות משותפת של שני בני הזוג, ניתן להסתפק בהסכמת אחד מבני הזוג.
54. סעיף 3 לחוק השליחות התשכ"ה - 1965 קובע:
- " השליחות מוקנית בהרשאה, שבכתב או שבעל פה, מאת השולח לשלוח, או בהודעה עליה מאת השולח לצד שלישי, או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם".
55. בע"א 3563/92, עזבון המנוח מאיר גרטלר ז"ל נ' דבורה גרטלר, פ"ד מח (5) 489, קבעה כב' השופטת דורנר (כתוארה דאז), דברים היפים גם לעניינינו:
- "פעולה שעשה בן-זוג בנכס הרשום על שמו עם צד שלישי בתום-לב מחייבת את בן הזוג האחר. שכן ההנחה - המעוגנת בתנאים שביסוד חזקת השיתוף: יחסים הרמוניים בין בני הזוג וחלוקת תפקידים ביניהם במאמץ המשותף - היא כי בן הזוג שהנכס רשום על שמו פעל גם בשם בן הזוג האחר. הסביר זאת השופט ברנזון בע"א 25]446/69, בעמ' 819 "הזכות שביושר, המצויה במקרה כזה ביד בן-זוג אחד בנכס שהבעלות החוקית או החזקה החוקית היא בידי בן-הזוג השני, קיימת גם קיימת והיא פועלת כלפי כולי עלמא. אלא שפעולה בתום-לב בנכס כזה הנעשית על-ידי צד שלישי עם הבעל הרשום או המחזיק החוקי תופשת ומחייבת גם את בן הזוג השני מתוך הנחה, המסתברת מאליה, שהוא פועל גם על דעתו, אם ברשות מפורשת ואם ברשות מכללא המשתמעת מעצם השארת הבעלות או החזקה בידי אותו בן-זוג".
56. דברים אלו נאמרו אמנם בהקשר למקרה בו רישום הזכויות במרשם המקרקעין הוא על שם אחד מבני הזוג, אולם יש ללמוד ממנו גם לעניינינו. במקרה של בני זוג, וככל שמדובר בקבלת החלטות בעניין הבית המשותף, לרבות החלטה בדבר



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הצמדת חלק מהרכוש המשותף לאחת הדירות, הרי שחזקה על בעל דירה שחתימתו ניתנה על דעתו של בן הזוג, אשר הסמיכו בעל פה לייצגו. מכל מקום, צד ג', במקרה זה הנתבעים, יכלו להניח, על פי שתיקתו של בן הזוג אשר לא חתם, כי בן זוגו שחתם הוא שלוחו.

57. יש, אם כן, לראות בהסכמות בעלי דירות 29 (לגביה ממילא יש חתימות של שני בני הזוג) 25, 28, 41, 45, 46 כהסכמות שאין לפסול אותן אך מהטעם כי ניתנו על ידי אחד מבעלי הזכויות בדירה, שכן חזקה כי ניתנו בהסכמת בן הזוג האחר. נותר לבחון, אם כן, מה דינה של הסכמת דירה 31, שכן לגביה נטען כי קיימות ראיות פוזיטיביות לכך שהסכמת אחד מבני הזוג לא ניתנה על דעת בן הזוג השני. לגבי תת חלקה 31- הרי שבנספח יט' לתצהיר עופר בביאן (להלן: "בביאן")- "רשימת המתנגדים" - (להלן: "רשימת המתנגדים") צורפה חתימתה של הגב' ורדי מיום 24.11.11. נספח א' 4 לכתב ההגנה הוא מסמך שכותרתו "הסכם" מיום 22.12.11 ובמסגרתו ניתנת לכאורה הסכמת מר זאב ורדי לבנייה המבוקשת. נראה, אם כן, כי בהסכם זה ניתן לראות משום הסרת ההתנגדות שכן ניתנה בו הסכמה מפורשת לבנייה תמורת התנאים המפורטים בו (כך למשל, תשלום של 30,000 ₪ לצורך ריצוף הרחבה, שיפור חזית הבניין וכד'), והוא ממועד מאוחר למועד ההתנגדות. אמנם, הנתבעים לא העידו אף אחד מבני הזוג ורדי, אולם, כאמור, ככל שסברו התובעים כי יש מחלוקת בין בני הזוג וכי הסכמה זו לא ניתנה על דעת שניהם, הרי שנטל ההוכחה עובר לכתפיהם על מנת להראות שההסכמה אשר הוגשה בכתב לאו הסכמה היא. דא עקא, כי התובעים בחרו שלא להעיד אף אחד מבני הזוג ולפיכך חזקה כי עדות זו הייתה משמשת לרעתם (ראה: ע"א 548/78 שרון נ' לוי פ"ד לה (1) 736 (1980), בעמ' 760, ע"א 635/89 אנקונה נ' גוטמן תק-על 90 (3) 705 (1990), ע"א 27/91 קבלו נ' שמעון פ"ד מט (1) 450 (1995); יעקב קדמי על הראיות - הדין בראי הפסיקה (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד), עמ' 1650). לפיכך, אינני מוצאת לנכון לפסול את ההסכמה אך בשל היותה חתומה על ידי מר ורדי לבדו, גם נוכח העובדה כי גב' ורדי הוסיפה חתימתה ל"רשימת המתנגדים" למוסדות התכנון במועד מוקדם יותר.

58. אפנה עתה לבחינת הטענה לפיה יש לפסול לכאורה הסכמות בכתב בעוד שקיימות ראיות כי אותם בעלי זכויות הגישו התנגדויות לבנייה למוסדות התכנון. טענה זו העלו התובעים ביחס לתת חלקה 34 (גולדברג), תת חלקה 40 (ליונס), תת חלקה 45 (קליק). בהקשר לקליק טענו גם התובעים כי יש שוני בין חתימת משה קליק בכתב ההסכמה לבין חתימתו על ההתנגדות, בטענה זו נדון בהמשך, וכן תת חלקה 46 (מאיר).

59. באשר לתת חלקה 34 (גולדברג) נטען כי הגב' אולה גולדברג הגישה התנגדות (נספח ב' לתצהיר בביאן) דבר הפוסל את הסכמתה אשר צורפה כנספח א'1. בחינת ההתנגדות אשר צורפה כנספח ב' לתצהיר בביאן מעלה כי היא הוגשה ביום 9.12.10 לעיריית ירושלים, זאת בעוד ההסכמה המצורפת כנספח א' לכתב ההגנה הנה משנת 2012 (לא מצוין תאריך מדויק). לפיכך, יש להניח כי הסכמה מאוחרת זו באה במקומה של ההתנגדות. מכל מקום, כאמור, התובעים בחרו שלא להעיד את הגב' גולדברג.

60. כאמור לעיל, ב"רשימת המתנגדים" צוין מועד חתימתו של כל אחד מהמתנגדים. כך, חתמה ליונס (תת חלקה 40) על ההתנגדות ביום 24.11.11, קליק (תת חלקה 45) חתם ביום 24.11.11, וריק וציפורה מאירס (תת חלקה 46) חתמו ביום 23.11.11. עיון ב"הסכמות" אשר צירפו הנתבעים לכתב הגנתם מעלה כי ליאנס חתמה לכאורה על הסכמתה ביום 5.8.11 (נספח א' 8 לכתב ההגנה), דהיינו קודם להתנגדות, דא עקא, כי בסיפא לאותה הסכמה הוספה בכתב יד הערה בדבר חזרתה מההתנגדות וזאת ביום 18.1.12. חתימת קליק על ההסכמה ניתנה ביום 2.7.11 (נספח א' 11 לכתב ההגנה), אולם גם כאן הוספה בכתב יד הערת הבהרה מיום 18.1.12. לגבי מאירס, צורפה הסכמת ציפורה מאירס מיום



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

28.6.12. עולה, אם כן, כי ההסכמות אשר צורפו לכתב ההגנה ניתנו במועד מאוחר ממועד החתימה על ההתנגדויות ולפיכך, ובהעדר כל עדות המלמדת אחרת, ניתן לראות בהסכמות אלו ככאלו שביטלו את ההתנגדויות המוקדמות יותר של בעלי הדירות הרלוונטיות.

61. בהקשר זה יש לציין כי הנתבע 3 (להלן גם: "גולדפילד") בעדותו הבהיר כי לאחר שההתנגדויות נדחו וניתן היתר הבנייה, חלק מהמתנגדים לא עמדו עוד על ההתנגדותיהם ונסללה הדרך להגיע עמם להסדר מוסכם, כפי שארע בפועל. בנושא זה עדותו של גולדפילד מקובלת עלי ומתיישבת גם עם מועדי ההסכמות ומידת ההיגיון, כך שלא מצאתי לנכון לפסול את הסכמות בעלי תתי חלקות 40,45,46 אך מן הטעם ששם מופיע גם כמתנגדים לבניה (כאמור, במועד המוקדם למועד מתן ההסכמות).

62. כאן המקום לבחון האם יש לפסול את הסכמת תתי חלקה 45 מטעם אחר עליו הצביעו התובעים, היינו שוני נטען בין החתימה על ההסכמה (נספח כא' לתצהיר בביאן) לחתימה על ההתנגדות ברשימת המתנגדים. הבדל זה, לשיטת התובעים, מטיל ספק בנוגע להסכמה הנתענת. במבט ראשון בנספח כא' אל מול נספח יט' לתצהיר בביאן אכן קיים הבדל נראה לעין בין חתימת קליק בשני המסמכים. דא עקא, כי אם בוחנים את חתימת קליק בנספח כא' שלא בטור ה"חתימות" אלא בטור ה"שם" עולה כי חתימתו בטור השם נראית דומה ואף זהה לחתימתו על גבי "רשימת המתנגדים". חתימה זו אף דומה עד זהה לחתימתו על גבי ההסכמה אשר צורפה כנספח 11 לכתב הגנתו. לפיכך, לא מצאתי כי יש לפסול את ההסכמה הנתענת, אף לא מטעם זה.

63. מה דינן של הסכמות אשר ניתנו לטענת התובעים, בעל פה? כזכור, טענו התובעים כי בעלי הזכויות בתתי חלקות 26 (שפירא) ו-39 (תאומים) נתנו הסכמתם בעל פה להרחבת דירות הנתבעים.

64. הלכה היא, כי גם הסכמה על פה הסכמה היא, ובלבד שתהא מוכחת בראיות מספיקות. בפסק דינו המנחה של בית המשפט העליון, ע"א 815/81, יעקב כליפא ו-2 אח' נ' אלי שאול ואח', פ"ד לו(3), 78, עמ' 84-85, הכיר בית המשפט בתוקפה המחייב של הסכמה בעל פה בין בעלי דירות בבית המשותף -

"... מובן מאליו, שהסכמה בעל-פה חייבת להיות מוכחת בראיות מספיקות. אם היא מוכחת כך, אין כל חשש לאי-ודאות. הרי סעיף 23 של חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, מאפשר, בדרך כלל, עשיית חוזה כלשהו בהסכמה בעל-פה. אין לראות טעם, מדוע נכונות זו של המחוקק לתת תוקף להסכמה בעל-פה לא תחול גם על הסכמת בעלי הדירות בבית משותף לטובת אחד מהם..."

ראה לעניין זה גם: ע"א (חיפה) 1020/03, בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף, תק-מח 2004(1), (להלן - "פרשת בובליל") 5244, ע"א 19/81 בנימין ביבי נ' ד"ר קרל הורברט ו-5 אח', פ"ד לו(2), 497, ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטר, פד"י לא 382(1).

65. יש לבחון, אם כן, האם אכן הוכחו ההסכמות הנתענות בראיות מספיקות.

66. באשר לתתי חלקה 26, הרי שבעליה הרשומים היא "שפירא דינה אסתר". אין חולק כי הגב' דינה אסתר שפירא נפטרה. בנסיבות אלו טענו הנתבעים כי יש בידם את הסכמת בתה, אשר גרה בדירה במקום אמה, הגב' שרה ג'וי שפירא (להלן: "שפירא"). הצדדים הבהירו כי למרבה הצער נפטרה גם היא לאחר מועד ההוכחות בהליך זה). להוכחת טענה זו הוגש תצהירו של גולדפילד (סעיף 12 לתצהיר) והוא אף נשאל עליה בחקירתו הנגדית.

67. בחקירתו הנגדית הבהיר גולדפילד בהקשר להסכמת הגב' שפירא כך:



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ת. "... פגשתי את הגב' שפירא לפני שלושה שבועות והיא סיפרה לי שהיא דיברה עם מר בביאן (לא יודע איזה אני מניח עופר) והיא סירבה להצטרף לתביעה והיא אמרה שאין לה בעיה עם הבנייה".
ש. אם זה המצב למה לא החתמת אותם? (צ"ל "אותה" - י.ע.ש).

ת. הגב' שפירא חוששת ולדעתי שלא בצדק שחתימה להסכמה לבנייה לשכן אחד תפגע בתביעה שהיא הגישה נגד שכן אחר שהיא מתנגדת לבניית המרפסת שלו. ניסיתי להסביר לה שאין קשר בין הדברים אך היא עמדה על חששה, לכן הסתפקתי בהסכמה בע"פ".

68. הטענה בדבר קבלת הסכמת שפירא בעל פה הועלתה בתצהיר גולדפילד מיום 20.5.13 מבלי שהובהרו שם נסיבות מתן ההסכמה. לפיכך עדות זו היא החומר הראייתי כולו עליו נשענת טענת ההסכמה מטעם תת חלקה 26. גם בהנחה שלא הייתה כל מחלוקת כי הגב' שרה שפירא היא אכן בעלת הדירה חלף אמה (שכן הנתבעים העלו טענות גם בעניין זה), אינני רואה כיצד ניתן לראות בהסכמה זו, כהסכמה המוכחת בראיות מספיקות, כנדרש בדין. לא ברור מה הוסבר לשפירא לגבי מהות הבנייה בגג, היקפו ופרטיו, האם הובהר לה נושא אחוזי בניה, האם הוסבר לה שמשמעות הסכמתה היא וויתור על זכויותיה הקנייניות בגג וכיוצא. בהיעדר פרטים אלו, הרי שטענת גולדפילד כי שפירא איננה מתנגדת לבנייה ("היא אמרה שאין לה בעיה עם הבנייה") ללא כל פירוט בדבר המידע שנמסר לה בנוגע לבנייה, אין בה די על מנת להוכיח את מתן ההסכמה מדעת. הנתבעים בחרו שלא לזמן את התובעת למתן עדות (אף על פי שבזמן מועד ההוכחות עוד הייתה בין החיים). אשר על כן, מצאתי כי טענת ההסכמה בעל פה של שפירא לא הוכחה בראיות מספיקות ולכן לא ניתן לקבלה כהסכמה לצורך סעיף 71 ב לחוק.

69. מפגמים דומים סובלת גם הסכמתו הנטענת של בעלי תת חלקה 30 (תאומים יונתן, להלן: "תאומים"). גם כאן, טענת ההסכמה עלתה לראשונה בתצהיר גולדפילד. אלא שבעניין זה לשם הוכחת ההסכמה צורף תצהירו של לובלינג. על תצהירו זה נחקר ביום 9.6.13. בהתאם לגרסתו של לובלינג, גולדפילד ביקש ממנו כי ייצור קשר עם תאומים, המתגורר בחו"ל, וזה אכן יצר עמו קשר טלפוני. בסעיף 5 לתצהיר לובלינג נכתב באשר למתן ההסכמה כך: "בשיחת הטלפון מר תאומים הביע את דעתו כי הוא אינו מתנגד לביצוע עבודות הבנייה, וכי הוא אינו מעוניין לחתום על מסמכים משפטיים. עם זאת, מר תאומים הדגיש באוזני כי אם במידה ויהיה הכרח לחתימה בכתב, אצור אתו קשר פעם נוספת".

70. לא לובלינג בעדותו ואף לא מי מהנתבעים הבהירו מדוע לא בחרו לפנות לתאומים קבלת מסמך הסכמה בכתב וזאת בשם לב לסיפא לסעיף 5 לתצהיר לובלינג שם צוין כי "מר תאומים הדגיש באוזני כי אם במידה ויהיה הכרח לחתימה בכתב, אצור אתו קשר פעם נוספת". הנתבעים לא הסבירו מדוע נמנעו מלפעול בעניינו של תאומים באופן דומה לזה שפעלו בעניינו של וגנר, בעלי תת חלקה 29, אשר אף הוא מתגורר בלונדון וממנו קיבלו הסכמה חתומה באמצעות הדואר האלקטרוני (כפי שעולה מהמצוין בנספח 3א לכתב ההגנה).

71. מחקירת לובלינג עלו עוד מספר ספקות בנוגע להסכמה הנטענת של תאומים. כך למשל, בעוד שבתצהירו ציין לובלינג כי במהלך 2010 או בסמוך לכך התבקש ע"י גולדפילד ליצור קשר עם תאומים, מחקירתו עלה כי דיבר עמו בפברואר-מרץ 2013. כך גם, לובלינג הבהיר כי לא נפגש מעולם עם תאומים, דהיינו הוא איננו מכיר אותו באופן אישי (דבר המעלה ספקות כיצד יכול היה לוודא כי הוא אכן משוחח עם תאומים). עוד עלה כי חמותו של לובלינג היא בעלת דירה בקומה העליונה בבית המשותף בכניסה אחרת, המבקשת לבצע בניה דומה לזו המבוקשת על ידי הנתבעים, כך שיש לעד אינטרס כלשהו בלאפשר את בניית הנתבעים כמבוקש.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

72. מכל מקום, גם אם ניתן היה על סמך עדות לובלינג לקבל טענה להסכמה עקרונית של תאומים, הרי שכלל לא ברור שאכן ההסכמה ניתנה באופן מפורש ולאחר שהוברר והובן לו מהי מהות הבנייה (לא נטען למשל כי נשלחו אליו התוכניות הרלוונטיות או אפילו כי הוסברה לו מהות הבנייה לפרטיה) וכי מדובר בויתור על זכויותיו הקנייניות. בנסיבות אלו, לא ניתן לקבל את הסכמתו הנטענת של תאומים כהסכמה לצורך סעיף 71ב.
73. הסכמה נטענת נוספת אותה יש לבחון היא לגבי **תת חלקה 36**, הרשומה במרשם המקרקעין בבעלות מדינת ישראל. התובעים צירפו כנספח 6 לכתב הגנתם את הסכמת מר שמחה לימן (להלן: "**לימן**"). בשם בעלי תת חלקה 36. סמכותו של לימן לחתום בשם מדינת ישראל כלל לא הובהרה ולא הוגשה כל הסמכה רשמית של לימן לחתום בשם מדינת ישראל כבעליה של תת חלקה 36. התובעים טענו כי לימן הוא שמנהל את הנכס עבור מדינת ישראל, אולם בכך לא די. ראשית, התובעים לא הציגו כל אסמכתא לעובדה כי לימן אכן מנהל את הנכס מטעמה של מדינת ישראל. שנית, אף אם היו מציגים ראיה כזו לא היה בה די בכדי להסמיכו לחתום בשם מדינת ישראל על הסכמתה לבנייה המבוקשת, שיש בה משום ויתור על זכויותיה הקנייניות בגג. זאת ועוד. מחקירתו הנגדית של גולדפילד התברר כי לימן הוא גיסו, פרט שלא נמסר קודם לכן בכתב ההגנה או בתצהירו של גולדפילד. במכלול נסיבות אלו הרי שלא ניתן לקבל את הסכמתו של לימן בשם מדינת ישראל.
74. באשר ל**תת חלקה 38**, הרי שבהתאם למרשם המקרקעין, בעלי זכויות החכירה בה הוא ברגר טיבור (דרכון L5749096). לכתב ההגנה צורפה כנספח 7 הסכמת מר יעקב ברגר ת.ז. 017426578. התובעים טענו כי אין זהות בין נותן ההסכמה לבעלים הרשום ועל כן אין לראות בהסכמה כהסכמה שניתנה כדין. דא עקא, כי התובעים בחרו שלא לזמן את מר טיבור ברגר למתן עדות, וזאת על אף שהטענה להסכמתו עלתה כבר בכתב ההגנה. בנסיבות אלו, ומשנתבעים עמדו בנטל המוטל עליהם להראות כי קיימת הסכמה, עבר הנטל לתובעים להוכיח כי הסכמה זו אינה כדין וכי לא ניתנה על ידי הבעלים הרשום. משבחרו שלא לזמנו לעדות, הרי שטענת ההסכמה לא הופרכה ועל כן ניתן לקבלה ככזו.
75. לגבי **תת חלקה 27**, אין חולק בין הצדדים כי מדובר במי שמתנגדים לבניית ההרחבה (התובעים 1-2, להלן: "**בביאן**"). דא עקא, לטענת הנתבעים יש לראותם, מכוח סעיף 71ב(ג) כמי שמסכימים קונסטרוקטיבית לבנייה המבוקשת, שכן בסגירת מרפסת דירתם ביצעו "הרחבה דומה". על אף שאינם חולקים כי סגירת המרפסת הנה בשטח קטן יותר משטח ההרחבה, טוענים הנתבעים כי עדיין נכון לראות בה "הרחבה דומה" שכן בסגירת המרפסת גזלו לכאורה התובעים 1-2 מזכויות הבניה של יתר בעלי הדירות בעוד שהם עצמם, ניצלו זכויות בניה המוקנות על פי תכנית 62 לדירות הגג בלבד. אלא, שהנתבעים העלו את הטענה בנוגע לתכנית 62 בעלמא, ללא כל ביסוס או הפניה לתכנית בכלל, ולהוראות הנקודתיות בה-עליהן הם מבקשים להסתמך- בפרט. מכל מקום, אינני סבורה כי ניתן לראות בסגירת מרפסת דירת בביאן, כעולה מתמונות אשר צורפו כנספח 6 לתצהיר גולדפילד, כ"הרחבה דומה". ראשית, כאמור, הטענה כי בניית ההרחבה על דירת הגג איננה גוזלת מזכויות הבניה של יתר בעלי הדירות לא בוססה כלל. שנית, גם בהתעלם מניצול זכויות הבניה, הרי שבשלב הראשון מבוקש להצמיד רכוש משותף לשטח דירות הנתבעים. שטח ההצמדה בפועל לשם הרחבת מרפסת בביאן קטן לאין שיעור משטח ההצמדה המבוקש לשם הרחבת דירות הנתבעים. לא ניתן כלל להשוות בין סגירת מרפסת בשטח של מטרים ספורים, להרחבת דירות הגג החולשות על פני שטחים ניכרים של עשרות מטרים ויותר. לא בכדי נקט המחוקק בלשון המונח "הרחבה דומה", בניגוד ל"הרחבה" בלבד, וזאת ללמדנו כי רק מי שביצע הרחבה דומה- הינו בשטח או באופי דומה, יחשב כמי שמסכים להרחבה המבוקשת (ראה: א. אייזנשטיין, שם, חלק



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

שלישי, עמ' 234, עש"א (מחוזי חי) 22123-10-10, חדד נ' זינגר, ע"א (מחוזי י"ם) 3235/02, אביב נ' גדולטר (פורסם באתר נבו)).

76. בנסיבות אלו, אין לראות את בביאן כמי שמסכימים קונסטרוקטיבית להצמדת שטח הגג לדירות הנתבעים ולבנייה עליו לשם הרחבת דירותיהם.

77. לשאלת ההסכמה של בעלי זכויות החכירה **בתת חלקה 37** (אברהם ופרל פיליפ ז"ל - להלן: **"בני הזוג פיליפ"**) הקדישו באי כוח הצדדים חלק ניכר מסיכומיהם. לכתב התביעה צורף מסמך שכותרתו **"הסכמת שכנים לביצוע עבודות הטענות היתר בניה"** (נספח ד' לכתב התביעה, להלן - **"מסמך הסכמת השכנים"**). במסמך הסכמת השכנים אשר נועד להגשת הסכמות שכנים לרשויות התכנון, מצהירים החותמים כי: **"ראינו את תוכניות הבנייה ואין לנו כל התנגדות לכך"**. לצד חתימות בעלי הדירות לא מופיע תאריך, אולם בסיום המסמך מופיעה **"הצהרת המבקשים"**, עליה חתום, בין היתר, גולדפילד, ועל פיה, בין השאר, מוצהר כי **"החתימות הנ"ל הן החתימות הנכונות של האנשים ששמותיהם נקובים לצידן"**. שמו וחתימתו של מר אברהם פיליפ מתנוססים על גבי מסמך זה. לצד ההצהרה מופיע התאריך **17.6.10**. הנתבעים מבקשים להיבנות על חתימה זו לשם הוכחת הסכמת פיליפ לבנייה נושא הליך זה.

78. לאחר בחינת מכלול החומר שהובא בפני, ספק רב אם ניתן לקבל את טענת הנתבעים להסכמת בני הזוג פיליפ, וזאת ממספר טעמים, עליהם אעמוד להלן. אקדים ואציין כי ממסמכים שצירפו התובעים עולה ספק בנוגע לכשירותם של בני הזוג פיליפ ליתן את ההסכמה מתוך הבנה ובדעה צלולה.

79. באשר למר אברהם פיליפ ז"ל (להלן: **"פיליפ"**) הוגש, מטעם הנתבעים, תצהירו של נוימן, הנשוי לאחייניתו של מר אברהם פיליפ ז"ל. בתצהירו נטען, בין היתר, כי נוימן היה מקורב מאוד לבני הזוג פיליפ וכי לפחות שנתיים טרם פטירתו סבל פיליפ מדמנציה קשה. בתצהירו נטען עוד כי לאור מצבו מונה נוימן, יחד עם מר יהודה דדוביץ' (להלן: **"דדוביץ'"**), כאפוטרופוס זמני למנות. מהמסמכים אשר צורפו לתצהיר נוימן עולה לכאורה התמונה הבאה - ביום **20.6.10** ניתנה **"תעודת רופא"** על ידי ד"ר מ. אומנסקי, שם, בפרק הממצאים ובהתייחס לפיליפ מצוין: **"מדובר בתמונה של דמנציה עם כושר שיפוט לקוי"**. לפיכך, ממליץ ד"ר אומנסקי להכריז על פיליפ כפסול דין שכן **"הנדון אינו מסוגל לדאוג לענייניו ולפי כך זקוק למינוי אפוטרופוס על גופו ורכושו"**. כמו כן, צורף **"צו מינוי אפוטרופוס"** מיום **6.8.10** ולפיו מונה נוימן ודדוביץ' לשמש כאפוטרופוסים זמניים, ביחד ולחוד, על רכושו של פיליפ לתקופה של שישה חודשים. כעולה מתעודת הפטירה, נפטר פיליפ ביום **22.9.10**.

80. לא נסתר מעיני כי מינוי נוימן כאפוטרופוס, על אף המלצת ד"ר אומנסקי, הנה אך לרכושו של פיליפ ולא לגופו, וכי פיליפ לא הוכרז כפסול דין. דא עקא כי ממהות המלצתו, ובהתווסף לכך מתוכן תצהירו של נוימן אשר לא נסתר בחקירתו הנגדית, עולה ספק באשר לכשירותו של פיליפ ליתן את ההסכמה הנטענת.

81. לאמור לעיל מתווספת תהיה נוספת המבוססת על כך שבניגוד למרבית ההסכמות להן טענו, לא צירפו הנתבעים לכתב הגנתם הסכם בינם לבין בני הזוג פיליפ, או יורשיהם. בהקשר זה יודגש כי רוב רובן של ההסכמות עליהן ביקשו הנתבעים להסתמך, הוגשו על דרך של הסכם כתוב עם בעלי הדירות (ראה נספחים 1א - 15 לכתב ההגנה), כאשר הנתבעים אינם מתבססים ומסתמכים באופן בלעדי על ההסכמות המופיעות במסמך הסכמת השכנים. היעדרו של הסכם כזה אומר דרשני.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

82. בנוגע לגב' פרל פיליפ (להלן: "פרל"), הרי שמנספחי תצהירו של נוימן עולה כי ביום 20.12.10 מונו נוימן ודדוביץ' במינוי קבוע כאפוטרופוסים על גופה ורכושה. כעולה מתעודת הפטירה נפטרה פרל ביום 23.3.11.
83. הנתבעים התנגדו נחרצות להגשת "תעודת רופא" עליה חתום ד"ר אומנסקי וטענו בסיכומיהם כי לא מדובר בתעודת רופא כדין, כי לא נקבע בה שקודם למתן התעודה לא היה פיליפ כשיר ליתן הסכמה, וכן כי מעדות גולדפילד עלה כי פיליפ הבין לחלוטין את מהות הסכמתו.
84. טענת הסכמה נוספת המצויה במחלוקת, הנה בנוגע לתת חלקה 43, הרשומה במרשם על שם גרוס פרנק וחנה בחלקים שווים. ראשית, נטען כי לא ניתנה הסכמת עזבונו של פרנק גרוס. שנית, התובעים טענו גם להיעדר הסכמתה של הגב' חנה גרוס. נספח א10 לכתב הגנה הוא הסכם שנחתם בין הנתבעים לגב' חנה גרוס (להלן: "גרוס"). על פי האמור בהסכם זה, נתנה גרוס את הסכמתה לבניית ההרחבה, כאשר סעיף 7 להסכם קובע כי – "אם וכאשר נבנה על הגג יעביר צד ב' (הנתבעים- י.ע.ש) לצד א' (גרוס- י.ע.ש) 5,000 ₪ - מזומן". תאריך ההסכם הוא 26.6.11. גרוס לא חלקה בעדותה על כך שנתנה הסכמתה זו, אלא שטענה, כי לאחר מתן הסכמתה, חזרה בה והודיעה על כך בעל פה לגולדפילד. מעדותה עלה ספק באשר למועד חזרתה מן ההסכמה, שכן בתחילה טענה כי היה זה שבועיים לאחר מתן ההסכמה (ראה פרוטוקול מיום 18.6.13, עמ' 8 שורה 7) ולאחר מכן טענה כי היה זה חודש-חודשיים לאחר מכן (ראה שם, עמ' 9 שורות 1-2), אולם בעדותה דבקה בכך כי חזרה בה מן הסכמתה והודיעה על כך לגולדפילד. טענתה זו לא נסתרה בחקירתה הנגדית. גולדפילד מצדו, הכחיש בעדותו מכל וכל את טענת גרוס כי חזרה בה מן ההסכמה, למרות שהודה כי הסכים הנקוב בהסכם, אשר עתיד היה להיות מועבר לגרוס עם הבנייה על הגג, כעולה מלשונו, לא הועבר אליה כלל (ראה שם, בעמ' 19 שורות 40-41). גם בנוגע להסכמה זו, עולות ספקות באשר לכשירותה, שכן כאמור אין חולק כי הסכים הנקוב בהסכם לא שולם לגרוס, ויש בכך בכדי ללמד לכאורה כי הנתבעים ידעו על חזרתה של גרוס מהסכמתה. השאלה נוספת בה יש לדון בהנחה שאכן בוטלה ההסכמה, היא באשר למועד חזרת גרוס מהסכמתה וכן באשר לטענת הנתבעים להסתמכות על הסכמתה ושינוי מצבם לרעה בעקבותיה.
85. תהיות וספקות אלו נותרות בעינן, שכן לא מצאתי כי יש צורך להכריע בסוגיות אחרונות אלו, ובין היתר, גם בכשירות, קבילות ומשקל האמור בתצהירו של נוימן ונספחיו. כעולה מהאמור לעיל, אף אם אקבל את הסכמת פיליפ ככשרה, וגם בהתעלם מהספקות באשר להסכמתה של גרוס, לכל היותר מצויים בידי הנתבעים הסכמותיהם של 15 בעלי דירות מתוך 24, דהיינו 62% מבעלי הדירות. אין רוב זה עונה על דרישת המחוקק בסעיף 71 לחוק לשם ביצוע הרחבה, ועל כן ממילא, אין בידי הנתבעים את הרוב הדרוש כדין לשם ביצוע הרחבת דירותיהם על חשבון הרכוש המשותף.
86. סיכומי של דבר, בידי הנתבעים לכל היותר, הסכמות של 15 מבין 24 הדירות בכניסה ג', דהיינו הסכמות של פחות מ-2/3 מבעלי הדירות (וחישוב זה הנו על הצד הזהיר, שכן הוא מונה את הסכמותיהם של גרוס ופיליפ על אף הספקות לעיל). אין די ברוב זה בכדי לצלוח במעבר משוכת דרישת סעיף 71 לחוק לפיה לשם ביצוע הרחבה יש צורך בהסכמת 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. לפיכך, אני קובעת כי אין בידי הנתבעים את הרוב הדרוש לשם הצמדת הרכוש המשותף בתחומי הגג לדירותיהם לשם ביצוע ההרחבות.
87. משנמצא כי הנתבעים אינם אווזים בהסכמת 3/4 מבעלי דירות כניסה ב' של הבית המשותף, הרי שאין צורך ללבן מחלוקת נוספת הנוגעת לטיב ההסכמות, היינו האם ההסכמות אשר ניתנו, ניתנו מתוך הבנה ומודעות מלאה לטיב הבניה המבוקשת, על כל הכרוך בה, ותוך ויתור על זכותם הקניינית של נותני ההסכמה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

88. כך גם מתייתר הדיון בשאלה האם מדובר בגג שהוצמד לכניסה ב' בתקנון המוסכם ולפיכך לשם הצמדת חלק משטחו לדירות הנתבעים די בהסכמת 3/4 מבעלי הדירות בכניסה זו, או שמא אין מדובר בגג שהוצמד לכניסה כלשהי ולפיכך לשם ביצוע ההרחבה יש צורך בקבלת הסכמת הרוב הקבוע בסעיף 71 לחוק מבין כל בעלי דירות הבית המשותף (72). בין כך ובין כך, היות וממילא אין בידי הנתבעים אף לא את הסכמת הרוב מבין בעלי כניסה ב' (והם בין כה וכה אינם טוענים כי בידיהם הסכמת רוב זה מבין כל בעלי הדירות), אין עוד צורך לדון בסוגיה זו.
89. דיון בשאלה נגזרת נוספת, אף הוא כבר איננו נדרש, היינו- מהו הרוב הדרוש לשם שימוש באחווי הבנייה לצורך ביצוע הבניה (השווה: רעא 11017/08, **נתן פל נ' מרדכי ליבוביץ'**, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 16.8.10).
- דוקטרינת תום הלב ושימוש לרעה בזכות**
90. במסקנה לפיה אין הנתבעים אוחזים ברוב הדרוש להם כדי לשם ביצוע הרחבות דירותיהם על שטח הגג המשותף, אין סגי. יש להמשיך ולבדוק האם אף על פי כן, אין מקום להורות על ביצוע ההריסה וזאת מכוח טעמים הנוצצים בדוקטרינת תום הלב והשימוש לרעה בזכות. יש לציין כי חלק הארי של סיכומי הנתבעים הוקדש לנושא זה, כאשר טענתם העיקרית היא כי סעד של הריסה הנו סעד חריג, כך שלא בכל מקרה של פגיעה בזכויות קנייניות יש להורות על ביצוע הריסה. לדידם, נכון במקרה זה להסתפק בסעד של פיצוי כספי, כגון תשלום דמי איזון.
91. נפנה לסקירת הרקע המשפטי ולאחר מכן ניישמו על המקרה דנן. עקרון תום הלב מעוגן בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג- 1973 (להלן: "**חוק החוזים**") ונפרש מכוח הוראות סעיף 61(ב) לחוק החוזים גם על פעילות משפטית וחייבים שאינם בגדרי החוזה. עקרון תום הלב הוחל באופן רחב, מתוקף פסיקת בתי המשפט, על כלל המשפט הישראלי (ראה למשל: ע"א 2643/97 **גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ**, פ"ד נז(2) 385, 400 (2003); ד"נ 7/81 **פנידר, חברה להשקעות פתוח ובנין בע"מ נ' קסטרו**, פ"ד לז(4) 673, 687 (1983); בג"ץ 1683/93 **יבין פלסט בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים**, פ"ד מז(4) 702, 708 (1993); ע"א 700/81 **פז נ' פז**, פ"ד לח(2) 736, 742 (1984)).
92. על אף שלהגנה על הקניין יש מעמד חוקתי על- חוקי (סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ע"א 6821/93, **בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מדגל כפר שיתופי**, פ"ד מט(4) 221), בעליו של נכס מקרקעין אינו נהנה מהגנה מוחלטת וזכותו מוגבלת מהפעלתה בשרירות. לעיתים, ייתכנו מקרים בהם מכוח עקרון תום הלב יוגבלו הסעדים להם זכאי בעל הזכות הקניינית, על אף שזכותו נפגעה.
93. בהקשר של נכסי קניין, קיימת גם הוראה ספציפית, שעניינה איסור השימוש לרעה בזכות, היא הוראת סעיף 14 לחוק הקובעת כי-
- " בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר".**
94. פסק הדין המנחה בסוגיה זו הנו פסק דינו המקיף של בית המשפט העליון אליו הפנו שני הצדדים, רעא 6339/97, **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה(1) 199 (להלן: "**פרשת רוקר**"). בפסק דין זה נדונה בין היתר הסוגיה האם ייתכנו מקרים של פגיעה שלא כדין בזכויות קניין, שבהם לא יוענק לנפגע הסעד המבוקש.
95. בפרשת רוקר הסכימו השופטים, על אף חילוקי הדעות ביניהם בעניין היקף ואופן יישום שיקול הדעת, כי לבית המשפט שיקול-דעת אם ליתן צו הריסה בעת פגיעה בזכות הקניינית, כאשר ייתכנו מצבים בהם תידחה תביעה להריסת מבנה לא



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

חוקי מכוח עקרונות תום לב ומניעות. על אף המחלוקות בין השופטים, גרעין ההלכה לפיו זכות הקניין אינה זכות מוחלטת הוסכם על הכול ואף קנה אחיזה איתנה בפסיקה (ראו למשל: ע"א 189/95 בנק אוצר החייל בע"מ נ' אהרונב פ"ד נג(4) 199, 287 (1999); ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נו(2) 385, 401-402 (2003); ע"א 790/97 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' אברהם, פ"ד נט(3) 697, 703-704 (2004); ע"א 6406/03 נאמני ההקדשות של העדה הספרדית בעיה"ק צפת ומירון נ' כמוס (טרם פורסם, 16.06.05), בפסקה 8; ע"א 8872/02 ארגוב נ' בן שלום (טרם פורסם, 7.11.05), בפסקה 22; רע"א 9626/05 נציגות הבית המשותף מרחוב הרב עמיאל 7, תל אביב נ' אבימור (טרם פורסמה, 16.11.05), בפסקה ה(4)).

96. בפרשת רוקר סברו כב' השופט אנגלרד, אל דעתו בעניין זה הצטרף כב' הנשיא (כתוארו דאז) ברק, כי מבחן נכון להפעלת שיקול דעת בתי המשפט בסוגיות שלילת סעד ההריסה בעת קיומה של פגיעה בזכויות קנייניות, הוא מבחן ה- "שקילה אובייקטיבית של האינטרסים ההדדיים לאור כל נסיבות המקרה" (יוער כי התוצאה אליה הגיעו שני שופטים אלו שונה היא, אולם שניהם הסכימו ליישום מבחן זה במסגרת הפעלת שיקול דעת השיפוט).

97. כב' השופט טירקל מסתייג ממבחן "שקילת האינטרסים ההדדיים". השופט טירקל, נמנע מלקבוע אמות מידה קשיחות לעניין הפעלת שיקול דעת, אך יחד עם זאת, הוא מונה בפסק דינו את השיקולים העיקריים אשר לדעתו ראוי שינחו את שיקול דעת בתי המשפט בבואם להגביל את בעל זכות הקניין מלממש את זכותו:

"השיקול הראשון הוא העוצמה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין, והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי- משני בחשיבותו לקודמיו- הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי הדין. לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמא, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה על ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול דעתו של בית המשפט, עד בלי השאיר לו שריד..." (ראה בפסקה 17 לפסק דינו).

(יוער כי על אף האמור לעיל, מקובלת גם על כב' הנשיא ברק גישתו העקרונית של השופט טירקל, לעניין קביעת רשימה (שאינה סגורה) של שיקולים בהפעלת עקרון תום הלב בגדרי הקניין).

98. עוד קובע כב' השופט טירקל כי אין בית המשפט נדרש לבחון את מניעי המתנגדים לאורך זמן ההתנגדות מראשיתה, אלא -

"האם פעלו בתום לב כאשר עשו שימוש בזכותם לתבוע את הריסת המבנה, אחרי שעתרו לבית המשפט למנוע את הקמתו מלכתחילה"
(ההדגשה במקור).

כב' השופט טירקל מוסיף ומבהיר כי-

"יש מקום לעמוד על ההבחנה, משום שמימושה של זכות קניין אינו דומה להגנה עליה מפני פגיעה שלא כדין. שנפגעה הזכות שלא כדין ונשקלת הסרת הפגיעה, נוטה, דומני, כף תום הלב לזכותו של הנפגע יותר מאשר היא נוטה לזכותו בשלב של מימוש הזכות בטרם נפגעה..." (ראה בפסקה 19 לפסק דינו).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

99. לעניין אופן הפעלת שיקול הדעת מוסיף כב' השופט טירקל גם את ההתייחסות הנכונה, לשיטתו, למבחנים מסוג של "מאזן הנוחות", או "שקילת האינטרסים ההדדיים" –

"בבואנו לבחון את השימוש שעושה פלוני בזכויות הקניין שלו או את ההגנה שלו עליהן במבחנים של תום לב, יש להיזהר מאוד כאשר באים לשקול נזק מול תועלת. מאזן כזה אינו עולה בקנה אחד עם מהותה של זכות הקניין, שבעליה רשאי, בדרך כלל, לעשות או שלא לעשות בה כאוות נפשו, בלי שהתועלת הכלכלית המופקת מהשימוש תעמוד לביקורת. מאזן כזה גם עלול להביא לתוצאות מרחיקות לכת ובלתי רצויות: אם ימצא בית המשפט שזקו של הפוגע בזכות גדול מהתועלת שיפיק בעל הזכות מהסרתה של הפגיעה, יהיה רשאי לאשר את הפגיעה וכך לשלול מן הבעלים את זכותו. משמעות הדבר היא הפקעה של זכות הקניין מכוח שיקולים הזרים למהותה. אין זה מתקבל על הדעת.

עוד ייאמר, כי המצדדים בעריכת מאזן של נזק מול תועלת מתייחסים לרוב לתועלת הכלכלית, הנמדדת בערכים כספיים. אולם גם תחושת הביטחון של בעל נכס – הנובעת מן הידיעה שקניינו מוגן וכי מי שינסה לפלוש לנכסיו יסולק – היא בגדר תועלת חשובה, אפילו אינה נשקלת בכסף. גם מטעם זה יש להגן על זכויותיהם של המשיבים ברכוש המשותף ואין להתעלם מהן רק משום שהמערערים יפיקו מהרכוש המשותף תועלת גדולה יותר, מבחינה כלכלית, מזאת שיפיקו ממנו המשיבים. (ראה בסעיף 21 לפסק דינו).

100. כב' השופט חשין, מסתייג אף הוא ממבחן "שקילת האינטרסים ההדדיים". באשר להפקעת שיקול הדעת, הוא קובע, בפסק דינו, בין היתר, את הדברים הבאים –

"הנחת היסוד לענייננו היא, שהנתבע פגע שלא כדין בזכותו של התובע, וכי התובע מבקש לחזור אל שלו, להחזיר את מצבו לכשהיה קודם הפגיעה. הנטל מוטל הוא אפוא על הנתבע, והנטל הוא לשכנע את בית המשפט על שום מה ולמה לא יחזיר לתובע את שלו; מדוע ולמה יש לראות את תביעת התובע כתביעה שלא בתום לב ושלא בדרך המקובלת; כיצד זה ומדוע משולה היא תביעתו של התובע לשימוש לרעה בהליכי בית משפט. מדברי חברי השופט אנגלרד ניתן ללמוד כי ראוי לנו לשקול באורח אובייקטיבי את האינטרסים ההדדיים של בעלי הדין – על רקע כל נסיבות המקרה – וכי שיקול זה ילמדנו אם פעל התובע בתום לב. אני מתקשה להסכים למבחן זה, שכן מטיל הוא על בית המשפט מעין הכרעה בחלוקת העושר בין התובע לבין הנתבע. כאילו אמורים אנו להכריע – מלכתחילה – כיצד ראוי לחלק את הרכוש העומד לחלוקה ונעשה צדק גם לתובע גם לנתבע.

ואולם חלוקת העושר נעשתה זה מכבר, ולא עלינו להחליט אם חלוקה זו הייתה כדין, אם לאו. נהפוך הוא: על יסוד הנחה שהנתבע גזל מן התובע מקצת רכושו,

השאלה היא אם הוריה על החזרת הרכוש תהא כה בלתי צודקת, כה בלתי ראויה, עד שנימנע מהורות כן. האם עמידתו של התובע על זכותו ניתן לראותה כשימוש לרעה בהליכי בית המשפט? הנחת היסוד היא, כזכור, שהתובע הוא בעלים נגזל (ולו נגזל באורח "אובייקטיבי"), ולא עליו הנטל להסביר מדוע מבקש הוא החזרת הגזל לידו. הנטל הוא על הנתבע, והוא החייב הסבר מדוע לא יחזיר את הגזל אלא ישלם פיצויים תחתיו ...



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לשון אחר: בעל־קניין אינו חייב להצדיק עצמו ואינו חייב להתנצל על שום מה מבקש הוא כי רכושו יוחזר לו. בעל־קניין אינו חייב להסביר ולפרש מדוע אין הוא מסכים כי זר ישב על כיסאו, מדוע מתנגד הוא כי נוכרי ישתלט על רכושו. החוק מזכה אותו בכך. החברה מזכה אותו במבוקשו. בית המשפט אינו מעסיק עצמו בצדק מופשט, ואין הוא יושב על כיסא־זרם לחלק רכוש בין תובע לבין נתבע על־פי עיקרון מופשט של "סבירות" ו"צדק". ה"סבירות" וה"צדק" הם שהנתבע יחזיר את המצב לקדמתו, והנטל עליו הוא – ונטל לא קל הוא – לשכנע את בית המשפט מדוע בנסיבותיו הספציפיות של עניין פלוני ראוי לחרוג מן הכלל ושלא להחזיר את הסטטוס־קוו־אנטה...." (ראה בפסקה 16 לפסק דינו).

101. לדעתם של השופטים טירקל וחשין מצטרף גם כב' השופט מצא, המבהיר בהקשר זה כך-

"... אף אני גורס שככלל זכאי בעל הזכות הנפגעת להחזרת זכותו לקדמתה. שיקול הדעת הנתון לבית המשפט, למנוע ממנו סעד כזה, נועד למקרים חריגים בלבד, כגון שלבעל הזכות לא נגרמה אלא פגיעה של מה בכך, בעוד שתיקון בעין של המעוות כרוך בהטלת נטל כבד ובלתי סביר על הפוגע... גם לוא סברתי ששיקול הדעת הנתון לבית המשפט לעניין הסעד הראוי בתביעה קניינית אינו מצומצם יותר משיקול הדעת הנתון לו בתביעה שעילתה נזיקת או חוזית, כסבור הייתי, שבכל הנוגע לפגיעת בעל דירה בבית משותף בזכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות השכנות, מוטל על בית המשפט להנהיג (כנושא של מדיניות שיפוטית) אמת מידה דוקנית....

הבטחת זכויותיהם של בעלי הדירות מפני פגיעה וניצול לרעה מצד שכניהם מותנית בהכרה בקיום זכות שבדין לקבלת סעד שיפוט אפקטיבי לכל מי שזכויותיו נפגעו".

102. עולה אם כן, כי מבחן "שקילת האינטרסים ההדדיים", אשר אומץ על ידי כב' השופט אנגלרד וכב' הנשיא ברק נדחה בפרשת רוקר על ידי דעת רוב שופטי ההרכב (כב' השופטים טירקל, חשין, מצא, ש. לוי. כב' השופטת שטרסברג-כהן לא התייחסה מפורשות לסוגיה זו בפסק דינה). אם כן, מלמדנו פרשת רוקר, כי לשם הפעלת שיקול דעתה של הערכאה השיפוטית בבחינת הסוגיה האם נכון להימנע ממתן סעד של הריסה בגין פגיעה בקניין, יש לעמוד על המבחנים אותם התווה השופט טירקל, בשים לב להערותיהם, הארוותיהם והבהרותיהם של יתר השופטים, שעיקרם פורטו לעיל.

103. אוסיף עוד, כי בהידרשו לנסיבות המקרה הפרטני בו דנה פרשת רוקר (פלישה במסגרת של בית משותף) נתן כב' השופט טירקל משקל להיעדר תום הלב מצד הפולשים (המערערים שם), אשר בנו על אף שידעו על התנגדות המשיבים:

"המערערים הזדרזו להשלים את הבנייה במשך פרק זמן של כחודשיים שבו לא עמד בתוקפו צו המניעה הזמני שניתן נגדם, אף שידעו כי המשיבים מתנגדים לבנייה וכי הגישו ערעור על פסק הדין שניתן לזכותם בבית משפט השלום, ערעור שבסופו של דבר התקבל. על כך נאמר "אכן, גם להתנהגותו של הנתבע במקרים מעין אלה נודעת חשיבות, ועלינו לשקול אותה כנגד התנהגותו של התובע. לא הרי מסיג גבול בתום לב כמסיג גבול במצח נחושה" (וייסמן בספרו הנ"ל, דיני קניין- בעלות ושיתוף [68], בעמ' 63). המערערים עשו מעשיהם בעזות מצח ובכך העידו על עצמם שהם מקבלים עליהם את תוצאות הריסת המבנה והחזרת המצב לקדמותו. ההוצאות שיהיה עליהם לשאת בהן כדי להסיר את רוע מעלליהם אינן יכולות לשמש שיקול לטובתם" (שם, בפסקה 19 לפסק דינו).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

104. פרשת רוקר יושמה ונספגה בקרקע הפסיקה המאוחרת לה. פסק דין אליו הפנה ב"כ הנתבעים הנו פסק דינו של בית המשפט העליון – ע"א 8661/10, **יוסף נעמה נ' תמר טורקיה**, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 19.2.12 (להלן: "**פרשת נעמה**"). בפסק דין זה נדונה השאלה האם יש להורות על הסרת הפלישה למקרקעיו של המערער. כב' השופטת חיות חזרה על קביעות פרשת רוקר לפיהן קיימת לבית המשפט הסמכות שלא להעניק סעד לשמירה על זכות הקניין, מכוח עקרון תום הלב, והוסיפה את הדברים הבאים:

"יחד עם זאת, וככל שהדבר נוגע להגנה על זכות הקניין שומה על בית המשפט לעשות שימוש זהיר בשיקול-דעתו, וזאת בראש ובראשונה בשים לב למעמדה המיוחד של זכות זו כזכות חוקתית בשיטתנו המשפטית. הנה כי כן, אף שמעמדה המיוחד של זכות הקניין אינו מקנה לה חסינות מפני החלת עקרון תום הלב גם באותם מקרים שבהם נדרשת הגנה על הזכות מפני פגיעה בה, מחייב מעמדה הרם גישה מתונה מצד בית המשפט בבואו להגביל את אפשרות מימושה..."

ראה גם: רע"א 8186/07 **כרמל נ' ינקוביץקי** [פורסם בנבו] (1.1.2008),

105. בהפעילו את שיקול דעתו בפרשת נעמה, עשה בית המשפט העליון (כב' השופטת חיות בהסכמתם של השופטים ריבלין ומלצר) שימוש במבחנים שהתווה כב' השופט טירקל בפרשת רוקר, תוך שהוא נותן את דעתו, בין היתר, גם להערות כב' הנשיא ברק בפרשת רוקר בעניין יחסי הקרבה. בית המשפט בחן את טיב הזכות הקניינית, את היקף הפגיעה ומשך הפגיעה ואת עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה והתנהגותם של בעלי הדין. באותו מקרה נמצא כי מדובר בזכות בעלות, בשטח פלישה זעום באופן יחסי (מטרים ספורים), הפלישה בוצעה שנים רבות טרם שהמשיבה נכנסה להתגורר במקום (באותו מקרה בוצעה הפלישה 26 שנים לפני שהמערער הגיש את תביעתו) ומבלי שפניותיו המוקדמות של המערער כללו תלויות לעניין אותה הפלישה. בהצטברם של טעמים אלו נקבע כי מדובר במקרה "**הנמנה עם אותם מקרים חריגים**" שבהם על בית המשפט להפעיל את שיקול הדעת המסור לו שלא להורות על הריסה.

106. בהקשר זה יש להוסיף את הדברים הבאים. הפסיקה אשר דנה בבחינת "התנהגות הצדדים" במובן של עמידה על טעמי המתנגדים לבניה המבוקשת (אם תרצה - טעמי ההתנגדות לפגיעה כזו או אחרת בזכות הקניינית, במובן של קיום בתום לב), אמנם הכירה בסמכות הערכאות השיפוטיות להביא בגדר מכלול שיקוליהם גם את הסיבה הנעוצה בהתנגדות, אולם הדגישה כי רק התנגדות בלתי הוגנת, הנעוצה בקינטור או סיבות הנוגדות את שיטת המשפט, תהא כזו אשר נכון יהיה להתעלם ממנה ולא להביאה במסגרת מניין ההתנגדויות לבניה המבוקשת ברכוש המשותף.

107. כך למשל, בעניין נטלה (ע"א (חי) 835/08, **נטלה צבי נ' עטרה פרי** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 18.11.09, להלן: "**עניין נטלה**"), נדון בית משותף דו קומתי בן 6 דירות כאשר בכל קומה ישנן 3 דירות. באותו מקרה ביקשה המערערת להרחיב את דירתה אל מפלס הגג, שהוא רכוש משותף, לצורך הוספת 3 חדרים ובכללם ממ"ד, מרפסת וחדר שירותים, ואף קיבלה היתר מרשויות התכנון לשם כך. לאחר מתן ההיתר הוגשה תביעת המשיבים שם למתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על ביצוע הבנייה. המשיבים טענו כי אין בידי המבקשת רוב של 3/4 מהדירות להם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף, כנדרש בסעיף 271 לחוק. משנוכחה המפקחת על רישום המקרקעין בחיפה כי אכן אין בידי המערערת את הרוב הדרוש, הורתה על קבלת התביעה מטעם זה בלבד. על אף דחיית הערעור לגופו של עניין, בית המשפט המחוזי,



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בדעת רוב (כב' השופט זרנקין וכב' השופטת וסרקרוג) קבעו כי על המפקחת להידרש גם לטעמי ההתנגדות ואין די בבחינה אריתמטית של הרוב הקבוע בחוק. באותה מקרה, נקבע מפי כב' השופטת וסרקרוג כך:

" כשם שנתונה למפקחת הסמכות לבחון את הפגיעה בזכותו המהותית של המיעוט ואף לבטל כליל את החלטת הרוב, כך נתונה הסמכות לעשות כן כאשר מדובר בהתנגדות הרוב ועליה לבדוק את נימוקי ההתנגדות. כל זאת גם אם הבדיקה הנדרשת תיעשה בזהירות ותבחן אם אכן מדובר בהתנגדות סתמית, שאינה עניינית (בהבדל מהתנגדות בלתי סבירה לפי סעיף 59ג(ד) לחוק), כדוגמת התנגדות אשר יש בה כדי להצביע לכאורה, על שימוש לרעה במימוש זכות הקניין או שמא מדובר בהתנגדות ממניעים ענייניים. כך למשל, אם ההתנגדות של הרוב "המאורגן", או רוב הנתון בידי אדם אחד, בהיותו הבעלים של מספר דירות בבניין, נעשתה מכוח כוונת קנטור או בשל מוצא או מסיבות אחרות שנוגדות את עקרונות שיטת המשפט, ואשר אין להם דבר או חצי דבר, עם הפגיעה בזכות הקניינית לכשעצמה, לא יהיה מקום לאשר את ההתנגדות

...

בענייננו, התייחסתי למונח התנגדות סתמית שעניינה כאמור, התנגדות בלתי הוגנת, בלתי ראויה ואשר יש בה כדי לפגוע בעקרונות יסוד של השיטה, התנגדות שאינה נוגעת למעשה לפגיעה בזכות הקניין ככזו, עד כדי שימוש לרעה באותה זכות".

108. בעש"א (חי) 17181-05-11, גורי אברהם נ' יאיר פדאל, (ניתן ביום 20.9.11, פורסם ב"נבו"), הוסיפה כב' השופטת וסרקרוג את הדברים הבאים:

"ראוי להבחין היטב בין עצם השאלה אם בעל דין המתנגד לבקשת שכנו לבנות ברכוש המשותף יכול לבוא לבית המשפט ולומר "מתנגד אני", ללא הוספת כל נימוק, ודי בכך כדי למנוע הבנייה, ולמעשה לצמצם או למנוע את סמכותו של בית המשפט או של המפקחת לדרוש פירוש נימוקי ההתנגדות, לבין היקף יישום סמכותו של בית המשפט לבקר את הנימוקים שהועלו.

בשאלה הראשונה שהיא העקרונית, אם לאור האמור בסעיף 71 לחוק המקרקעין שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה" עומדת הזכות למתנגד שלא לפרט את נימוקיו להתנגדות, אפילו אלה סתמיים ואפילו נוגדים הם את עקרונות שיטת המשפט ותום הלב – שהוא אחד מעקרונות היסוד בשיטה- סבורה הייתי וסבורה אני שאין לאפשר התנגדות ללא הנמקה.

בשלב השני שלאחר הבאת הנימוקים סמכותו של ביהמ"ש לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר.

אכן, אין לאפשר לדעת התנגדות סתמית שאינה עניינית או שיש בה משום שימוש ברעה לזכות הקניין, כך נאמר על ידי בפס"ד צבי והוספתי שם כדוגמא כאשר בעלים של מספר דירות בבניין מתנגדים מתוך כוונת קנטור או בשל "מוצא או נסיבות אחרות הנוגדות את עקרונות שיטת המשפט ואשר אין בהם דבר או חצי דבר עם הפגיעה בזכות הקניינית לכשעצמה...".

ראה עוד: עש"א (מחוזי חיפה) 13877-07-09, אילן קסרי נ' שאחב שלומוב, (פורסם ב"נבו").

109. בעניין רסלר (רע"א 7911/10, עו"ד יהודה רסלר נ' חנה תירוש (פורסם ב"נבו". ניתן ביום 22.11.10), נדון נושא של התקנת מעלית, כאשר לבעלי הדירות המעוניינים בהתקנתה רוב של 11/18 דירות בלבד (בעוד סעיף 59 לחוק דורש



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הסכמת 3/4 מבעלי הדירות אשר ניתנה באסיפה הכללית). על אף היעדר הרוב הדרוש, דחתה המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב את התנגדות המערער לבניית המעלית, שכן מצאה כי ההתנגדות הייתה שלא בתום לב. בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו, ובקשת רשות ערעור אשר הוגשה לבית המשפט העליון נדחתה אף היא. כבי' השופט הנדל, דחה את בקשת רשות הערעור, תוך שהוא עומד על נסיבותיה החריגות של הפרשה. באותו מקרה, התנגד המערער לבניית המעלית בשל הקשיים שיגרמו ללקוחות משרדו, אשר יתקשו להיכנס למשרד. אולם, נמצא כי שימושם במחסנים כבמשרד, נעשה מבלי לעמוד בתנאים עליהם הורתה ועדת התכנון ובכללם בניית כניסה נפרדת. בית המשפט העליון קבע, בין היתר, כי "הפגיעה בקניינו של המערער היא מצומצמת נוכח אי החוקיות השוררת בנכס, על כל משמעויותיה והיבטיה מבחינה משפטית".

110. הנה כי כן, גם עת עסקינן בזכויות קנייניות, בית המשפט אינו חותמת גומי, ועליו לתת את דעתו, מעבר לשאלת קיומו של רוב הקבוע בחוק, גם לשיקולים הנעוצים בטעמי ההתנגדות- בחינת תום לב של הצד המתנגד, האם ההתנגדות הוגנת ועניינית או שנעוצה בטעמים בלתי סבירים וקנטרניים. לכך יש להוסיף גם עמידה על היקף ועוצמת הפגיעה הנטענת, כאשר מעל כל בדיקות אלו מרחפת ההכרה כי היות ועסקינן בזכויות קנייניות, הרי שרק במקרים "חריגים ונדירים" ייתן בית המשפט יד להגבלתן מפני מי שפגע בהן שלא כדין.

111. אעיר עוד כי דברים אלו אף עולים בקנה אחד עם רוח הדברים בבשא (נצי') חרושת מתכת בית השיטה (בהח) בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ-אגף אשראים מיוחדים (פורסם ב"נבו". ניתן ביום 1.2.10), אליו הפנה ב"כ הנתבעים בסיכומיו. גם שם נקבע כי במקרים חריגים אין די ביישום טכני של לשון החוק, ויש להידרש לטעמים העומדים בבסיס הסירוב, כאשר אם ימצא כי ההתנגדות נוגדת את רוח החוק ותכליתו, יתערב בה בית המשפט (באותו עניין דובר בבחינת טעמיהם של בנקים, במסגרת התנגדותם להסדר נושים).

112. על רקע דברים אלו, יש לזכור עוד כי עסקינן בבית משותף. באשר למשטר הבתים המשותפים, חזרו ונשנו בפסיקה ההלכות המורות כי יש לנקוט זהירות רבה במתן הכשר לפגיעה בזכויות קנייניות. כך למשל, ניתן ללמוד מדברי השופט טירקל בפרשת רוקר :

" בנושא רגיש זה של יחסי שכנים בבית משותף, יש להקפיד במיוחד על שמירת זכויותיהם של בעלי הדירות ולהיזהר שלא לפרוץ בהן פרצות. השארת הבנייה מסיגת הגבול על כנה במקרה הנדון עלולה לפתוח פתח לכך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש המשותף שבבית המשותף, וכל דאלים יגבר על שכניו שומרי החוק". (ראה בפרשת רוקר, פסקה 20 לפסק דינו של כבי' השופט טירקל).

113. ראה גם דבריו הידועים של כבי' השופט גולדברג בע"א 93/81, אליאס נ' שיפר, פ"ד לו (2) 444 :

" אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד כדי שכל בר דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של משטר הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם."

מן הכלל אל הפרט



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

114. הנה כי כן, כפי שמורה ההלכה הפסוקה, מוסמכת הערכאה השיפוטית שלא ליתן סעד שעניינו הגנה על הקניין, מכוח עקרון תום הלב ושימוש לרעה בזכות. אולם, מקרים אלו של הימנעות מהושטת הסעד הם חריגים ונדירים ולא בנקל ימנע מתן הסעד המבוקש, ככל שמדובר בהגנה על זכויות קנייניות.
115. יישום המבחנים שהתווה כב' השופט טירקל בפרשת רוקר, מובילנו למסקנה כי המקרה דנן איננו נמנה על מקרים חריגים ונדירים אלו.
116. **העוצמה של הזכות הקניינית שנפגעה** - אין חולק כי עסקינן בזכויות בעלות וחכירה לדורות במקרקעין, עליה מבקשים התובעים להגן. זכויות אלו הן, ללא כל ספק, זכויות חזקות ועוצמתיות, ככל שעסקינן בזכויות במקרקעין.
117. **עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה** - מדובר בפגיעה שמשמעה השתלטות על שטח רחב היקף בגג הבית המשותף. היקף הפגיעה, אם כן, אינו דבר של מה בכך כלל וכלל. תפיסת שטח הגג המבוקשת היא תפיסה כדרך קבע, ואיננה ארעית או חולפת. עוצמתה של הפגיעה בזכות, אם כן, היא ניכרת.
118. אין חולק כי **עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות גבוהה** היא. משמעות הסרת הפגיעה במקרה הנדון היא הריסה של בנייה שכבר הושלמה, בניה בה השקיעו הנתבעים זמן לא מבוטל וממון רב. תוצאה זו קשה היא ללא כל ספק. יחד עם זאת, מבחן התוצאה, לדידו של השופט טירקל, הוא **"מבחן משני בחשיבותו לקודמיו"**, שכן **"ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול דעתו של בית המשפט, עד בלי השאיר לו שריד..."**. כאן גם המקום להזכיר כי שיקולי דעת הרוב בפרשת רוקר אשר דחו את מבחן "איוון האינטרסים" הדגישו כי כמעט כל אימת שיעשה שימוש במבחן זה תהא ידו של הפוגע על העליונה, שכן משמעות הריסת בניה קיימת הנה ברוב המקרים קשה יותר משמירה על זכות קניין אשר במובן מסוים הנה "ערטילאית".
119. במקום זה נודעת חשיבות למבחן הרביעי שהציע השופט טירקל הוא מבחן **"התנהגותם של בעלי הדין"** - הנתבעים החלו בביצוע הבניה על הגג כשבידם אמנם היתר בניה כדן, אך כאשר קיים ספק בשאלה האם יש בידם את הסכמת רוב בעלי הדירות כנדרש בסעיף 71 לחוק. דברים אלו עלו כבר בהחלטת ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז ירושלים (להלן: **"ועדת הערר"**) שם אמנם אושר מתן ההיתר, אולם נקבע בה מפורשות כי לא הוצגו בפני הועדה ההסכמות הדרושות בחוק המקרקעין (ראה בעמ' 10 להחלטת ועדת הערר, שורות 15-16). עם זאת, מכוח ההלכה הפסוקה (דנמ 668/11, בני אליעזר בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים (פורסם ב"נבו")) קבעה ועדת הערר כי ניתן ליתן את ההיתר שכן קיימים **"תימוכין קנייניים"** לקבלת ההסכמות כדן (ראה החלטת ועדת הערר, ערר מס' 120/12+114-1 נספח 4 לתצהיר גולדפילד).
120. אמנם, לאחר דחיית הערר השיגו הנתבעים הסכמות נוספות של חלק מבעלי הדירות, אולם זמן קצר לאחר התחלת הבניה הוגשה תביעה זו, במסגרתה הוטלה בספק קבלת הסכמות בעלי הדירות כדן לבנייה זו. הנתבעים הם שגמרו אומר להמשיך בבניה עד כדי השלמתה, וזאת על אף שידוע היה להם כי ייתכן ובסופו של ההליך יימצא כי אינם אווזים בהסכמת בעלי הדירות כדן. במצב דברים זה אין לי אלא לקבוע כי הנתבעים שמו כספם על קרן הצבי. עם כל הצער הכרוך בהריסת הבניה אשר הסתיימה זה מכבר (תוצאה קשה שאינה נסתרה מעיני, ולא בנקל אני מורה עליה), היה על הנתבעים להביאה בחשבון במסגרת מכלול שיקוליהם טרם קבלת החלטתם להמשיך בבנייה. בהקשר זה אציין כי אינני סבורה כי העובדה שהתובעים נמנעו מלפנות בבקשה לקבלת צו מניעה מלכתחילה יש בה כדי לשנות מסקנה זו. גם



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בהיעדרו של צו מניעה, צריכים ויכולים היו הנתבעים שלא להמשיך בבנייה, כל עוד תלויה ועומדת התביעה, ועד שיתבהר המצב העובדתי והמשפטי לאשורו.

121. כפועל יוצא, הרי שהסתמכותם של הנתבעים על הסכמות בעלי הדירות ברף נמוך מזה הנדרש בחוק, ושינוי מצבם לרעה בעקבותיה, איננה יכולה להקים להם טענת מניעות ושיהוי כנגד התובעים.

122. אעיר, כי במבט ראשון ייתכן ותוצאה זו נראית כי סותרת את מגמת המחוקק בתיקון 18 לחוק, אשר מטרתו הייתה לנצל באופן מיטבי את הקרקע ולאפשר הרחבת דיור על פני שטחים ברכוש המשותף. המחוקק אף ביקש להימנע משימוש שרירותי בזכות הקניין ומטעם זה הפחית את רף ההסכמות הנדרש לשם ביצוע הרחבה (מהסכמת כל בעלי הדירות, כפי שהייתה קודם לתיקון 18, להסכמת רוב מיוחס מהם). אלא, שעיון בדברי הכנסת ובדברי ההסבר לחוק [ראה: "דברי הכנסת", כרך 133, עמ' 1797, הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש המשותף) התשנ"ה-1994 (הצעות חוק, התשנ"ה, עמ' 114)], מלמדים כי כוונת המחוקק לא הייתה לפגוע בזכויות הקניין של יתר בעלי הדירות בבית המשותף בצורה שאינה מידתית. זו גם הסיבה שהצעה להפחית את הרוב עוד יותר עד כדי 50% בלבד, נדחתה בדיוני הכנסת.

123. באשר לבחינת טעמי ההתנגדות: לדידי, די בכך שהתובעים, או המתנגדים בכללותם, מבקשים לשמור על זכויותיהם הקנייניות בגג, להן ערך כלכלי. הבנייה על הגג שללה מהנתבעים, לצמיתות, את האפשרות לעשות שימוש בשטח הגג אשר הוצמד בפועל, בעקבות ההרחבה, לדירות הנתבעים ויכולתם להנות ממלוא ערכו הכלכלי, הוגבלה אף היא.

124. לאחר עיון במלוא חומר הראיות ושמיעת עדי הצדדים, לא מצאתי כי טעמי ההתנגדות הם "קנטרניים" "בלתי סבירים" ועולים כדי היותם "מנוגדים לשיטת המשפט". אמנם, לא כל המתנגדים נימקו התנגדותם באופן ברור ומפורט, אולם נימוקים שעלו נוגעים, בין היתר, לשלילת זכויות בעלי הדירות בגג (ראה למשל עדות הגב' ציפורה הולנדר, פרוטוקול מיום 18.6.13, עמ' 2 שורות 22-23, הגב' חנה גרוס עמ' 8 שורה 43, עדות עופר בביאן, עמ' 13 שורות 41-46, כתב ההתנגדות של הגב' מלכה אהרונסון (נספח ו' לתצהיר בביאן-סעיף 1), הגבלת האפשרות לעשות שימוש בגג (ראה עדות הגב' ציפורה הולנדר לעיל), והחשש מפני אי יכולת לנצל את מלוא הטבותיה של תמ"א 38 (עדות הגב' מלכה אהרונסון, שם, עמ' 10, שורות 29-37, עדות מר עופר בביאן, שם, עמ' 13 שורות 37-46, עמ' 14 שורה 6) התנגדות מטעמים של פגיעה ביכולת המימוש המלאה של תמ"א 38, אף הוכרה כלגיטימית **בפרשת נטלה**. אעיר עוד, כי אף אם ניתן לממש את תמ"א 38 גם לאחר בניית ההרחבה, הרי שלא מן הנמנע כי שימוש זה יהיה מצומצם מזה הניתן לביצוע ללא ההרחבה.

125. אמנם, חלק מהנימוקים שהושמעו אינם נוגעים כלל לשמירה על הזכות הקניינית אלא למטרד הנגרם לבעלי הדירות כתוצאה מהבנייה, לטענת חלק מהמתנגדים (ראה למשל עדות הגב' דוריס שלזינגר, פרוטוקול מיום 18.6.13, עמ' 6 שורות 8-9, עדות הגב' חני גרוס, שם בעמ' 8, שורות 34-35), אולם, כאמור, אלו רק חלק מנימוקי ההתנגדות ואין לראות בהם חזות הכל.

126. אעיר עוד כי הטענה המרומזת לפיה ממילא לאחר הבניה נוצר גג חדש המהווה רכוש משותף, אין בה כדי לסייע לנתבעים. אם תתקבל הטענה, הרי שמשמעותה כי כל אימת שמדובר בבניית הרחבה על גג, מכוחו נוצר גג חדש, לא יהיה כל ערך או משקל להתנגדות בעלי דירות נוכח הפגיעה בזכויותיהם הקנייניות בגג הקיים.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

127. מכל מקום, בשים לב לפרשות נטלה, גורי ורסלר, ההתערבות השיפוטית בבחינת טעמי ההתנגדות היא מוגבלת ומצומצמת, וכאמור לא מצאתי שאלו עולים כדי טעמים בלתי הוגנים הנוגדים את ערכי היסוד של השיטה.

128. אם נחזור לפרשת נעמה, הרי שעל אף שבסופו של דבר נמנע בית המשפט מליתן צו הריסה במקרה מוכח של פלישה, הרי שאין הנדון דומה לראייה. באותו מקרה דובר בנתונים עובדיתיים השונים לחלוטין מעניינינו. בעוד ששם דובר בשטח פלישה זעום, במקרה דנן מדובר בשטח של עשרות מטרים, שטח נרחב מאוד החולש על חלק ניכר מהגג. כמו כן, שלא כבפרשת נעמה, אין המדובר בפלישה ישנה אלא בפלישה טרייה, שחלקה אף בוצעה תוך כדי הדיון בהליך זה. אינני רואה כיצד יש בקביעות פרשה זו בכדי לסייע לנתבעים דווקא, אשר הפנו לפרשת נעמה כאסמכתא מטעמים.

129. נוכח מסקנתי זו אינני נדרשת להכריע בטענות התובעים בנוגע להיעדר תום לבם של הנתבעים, בכל הקשור להליך קבלת ההסכמות, אשר נעשה לטענתם "במחשכים" בשיטת "הפרד ומשול", ובאופן בו מנעו הנתבעים, כביכול במתכוון, מקיום דיון באסיפה הכללית בדבר הבנייה ומשמעויותיה.

130. יש להעיר עוד כי העובדה שהנתבעים הגיעו לכדי הסכמה עם חלק מבעלי הדירות, לפיה, בין היתר, ישפצו את דרכי הגישה לבית המשותף בתמורה להסכמתם של האחרונים לבניית ההרחבה, ואף ביצעו שיפוץ זה בפועל, אינה יכולה לכבול את יתר בעלי הדירות. אינני דנה בהליך דנן בטובת ההנאה שצמחה לכאורה לבעלי הדירות עקב השיפוץ האמור, וממילא אין באמור בפסק דין זה בכדי לפגוע בזכויות הנתבעים לפעול בעניין במסגרת המתאימה.

131. הערה לפני סיום. ניסיונותיי להוביל את הצדדים לידי הסכמה לא צלחו, שכן התובעים עמדו על קבלת מלוא הסעד העיקרי וסירבו להסתפק בדמי האיזון אשר נתבעו כסעד חלופי. יש לקוות כי על אף מתן פסק הדין ישכילו הצדדים להגיע ביניהם לעמק השווה ולו לשם כינון יחסי שכנות טובה בבית המשותף.

סוף דבר,

132. התביעה מתקבלת.

133. ניתן בזה צו מניעה האוסר על הנתבעים לבנות על גג הבית המשותף.

134. על הנתבעים להרוס את כל הבניה שביצעו על גג הבית המשותף ולהשיב את המצב לקדמותו, וזאת בתוך 90 יום מיום המצאת פסק דין זה לידי בא כוחם.

135. מתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לחוק, אני מורה לרשמת המקרקעין בירושלים לרשום הערה בגוש 30246 חלקה 6, תתי חלקות 47 ו-48 לפיה: "קיים צו הריסה בנוגע לבניית ההרחבה בהתאם לפס"ד בתיק (מפקח) 344/12".

136. הנתבעים יישאו בהוצאות התובעים ושכר טרחת עורך דינם בסך כולל של 7,000 ₪.

ניתן היום, כ"ח טבת תשע"ד, 31 דצמבר 2013, בלשכתי, בהיעדר הצדדים.

יעל ענת-שרון
מפקחת על רישום מקרקעין